Landgericht Düsseldorf, 4b O 83/19

Datum:	11.05.2021
Gericht:	Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper:	4b. Zivilkammer
Entscheidungsart:	Urteil
Aktenzeichen:	4b O 83/19
ECLI:	ECLI:DE:LGD:2021:0511.4B.O83.19.00

Tenor:

1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

Smartphones und Tablets zur Durchführung eines Verfahrens zum Synthetisieren eines ersten und zweiten Audio-Ausgangssignals von einem Eingangssignal

zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn das Verfahren die nachfolgenden Schritte umfasst:

- das Filtern des Eingangssignals zum Erzeugen eines gefilterten Signals,

- das Erhalten eines Korrelationsparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,

- das Erhalten eines Pegelparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,

- das Transformieren des Eingangssignals und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal, wobei der Matrixvorgang von dem

Korrelationsparameter und dem Pegelparameter abhängig ist.

2. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen

Anordnungen zum Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Audio-Ausgangssignals von einem Eingangssignal

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wenn die Anordnungen Folgendes umfassen:

- Filtermittel zum Filtern des Eingangssignals zum Erzeugen eines gefilterten Signals,

- Mittel zum Erhalten eines Korrelationsparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,

- Mittel zum Erhalten eines Pegelparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal,

- Mittel zum Transformieren des Eingangssignals und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal, wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter und dem Pegelparameter abhängig ist.

3. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung – hinsichtlich der Angaben a) und b) unter Vorlage von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheinen, weiter hilfsweise Quittungen in Kopie, wobei Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können – darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie seit dem 30. Oktober 2009 Mittel gemäß Ziffer 1. zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland angeboten oder geliefert haben, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen

Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

4. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung – hinsichtlich der Angaben a) und b) unter Vorlage von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheinen, weiter hilfsweise Quittungen in Kopie, wobei Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können – darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie seit dem 30. Oktober 2009 Anordnungen gemäß Ziffer 2. in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der

Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

5. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1. und 2. bezeichneten Handlungen seit dem 30. Oktober 2009 entstanden ist und noch entstehen wird.

6. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, die unter Ziffer 2. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 9. April 2017 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents XXX (deutscher Teil des XXX) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte zu 2) diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst.

7. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

8. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 5 % der Gerichtskosten und 10 % der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1), die Beklagte zu 1) 45 % der Gerichtskosten und 40 % der außergerichtlichen Kosten der Klägerin und die Beklagte zu 2) 50 % der Gerichtskosten und 50 % der außergerichtlichen Kosten der Klägerin.

9. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 950.000 EUR und für die Beklagte zu 1) in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Als Teilsicherheiten werden für die Zwangsvollstreckung der Klägerin aus

Ziffer 1., 2. und 6.: 650.000 EUR,

Ziffer 3. und 4.: 200.000 EUR und

Ziffer 8.: 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents XXX (Anlage K 2; im Folgenden: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung der Erzeugnisse sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. 1

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des am 22. April 2003 unter Inanspruchnahme zweier Prioritäten vom 22. April 2002 und vom 12. Juli 2002 angemeldeten Klagepatents. Die Anmeldung wurde am 26. Januar 2005 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung am 14. Februar 2007. Die deutsche Übersetzung der in englischer Verfahrenssprache veröffentlichen Patentschrift wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung XXX geführt (vgl. Anlage K 2a). 2

Die Beklagte zu 1) hat am 10. Juli 2020 vor dem Bundespatentgericht in Bezug auf das Klagepatent Nichtigkeitsklage erhoben. Eine Entscheidung ist bislang nicht ergangen. 3

Das Klagepatent betrifft die Signalsynthese zweier ausgehender Signale auf der Grundlage eines Eingangssignals. Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche 1 und 7 lauten in der deutschen Übersetzung: 4

1. Verfahren zum Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Ausgangssignals (L, R) von einem Eingangssignal (X), wobei das Verfahren die nachfolgenden Verfahrensschritte umfasst: 5

- das Filtern des Eingangssignals (X) zum Erzeugen eines gefilterten Signals, 6

- das Erhalten eines Korrelationsparameters (r), der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R), 7

- das Erhalten eines Pegelparameters (c), der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R), 8

9

- das Transformieren des Eingangssignals (X) und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal (L, R), wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter (t) und dem Pegelparameter (c) abhängig ist.

und 10

7. Anordnung zum Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Audio- 11
Ausgangssignals (L, R) von einem Eingangssignal (X), wobei diese Anordnung Folgendes umfasst:

- Filtermittel (201) zum Filtern des Eingangssignals (X) zum Erzeugen eines 12
gefilterten Signals,

- Mittel (202) zum Erhalten eines Korrelationsparameters (t), der indikativ ist für eine 13
gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R),

- Mittel (202) zum Erhalten eines Pegelparameters (c), der indikativ ist für eine 14
gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R),

- Mittel (203) zum Transformieren des Eingangssignals (X) und des gefilterten 15
Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal (L, R), wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter (t) und dem Pegelparameter (c) abhängig ist.

Wegen des daneben geltend gemachten abhängigen Unteranspruchs 2 wird auf die 16
Klagepatentschrift verwiesen.

Die Klägerin ist ein Elektronikunternehmen und hält Patente unter anderem aus dem Bereich 17
der optischen Datenträgersysteme, sowie der Audio- und der Videokompression, insbesondere auch solche Patente, die für den MPEG-4 Advanced Audio Coding (im Folgenden: AAC) Standard (im Folgenden: AAC-Standard oder Standard) wesentlich sind. Die Klägerin gab gegenüber der International Organisation for Standardization“ (im Folgenden: „ISO“) und der „International Electrotechnical Commission“ (im Folgenden: „IEC“), die den Standard verabschiedeten, eine Erklärung ab, wonach sie bereit ist, Lizenzen an ihren AAC-relevanten Patenten zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen (im Folgenden: FRAND bzw. FRAND-Bedingungen = „fair, reasonable and non-discriminatory“) zu vergeben. Von der Erklärung ist auch das hiesige Klagepatent erfasst.

Der AAC-Standard verfolgt ein modulares Konzept, das die Erweiterung der Grundkonzepte 18
durch so genannte Tools vorsieht. Bestimmte Konfigurationen bzw. Tools werden im AAC-Standard zu Profilen zusammengefasst. Der AAC-Standard umfasst dabei drei Profile: das allgemeine AAC-Profil, das „High Efficiency AAC Profile“ (HE AAC) und das „High Efficiency AAC v2 Profile“ (HE AAC v2). Die in diesem Rechtsstreit relevante parametrische Stereocodierung ist Gegenstand des HE AAC v2. Wegen der Einzelheiten des im Standard normierten Parametric Stereo Tools wird auf Abschnitt 8.6.4 von Subpart 8 des geltenden Standards verwiesen, aus dem Auszüge als Anlage K3g zur Akte gereicht worden sind.

Der AAC-Standard stellt eine Kompatibilitätsanforderung für das Android-System von Google 19
insofern dar, als dessen Implementierung erforderlich ist, um die Zertifizierung für sog. „Google Mobile Services“ (GMS) zu erhalten. Dieser bedarf es wiederum, um „Google-Anwendungen“, insbesondere den Google Play App Store, Google Maps, Google Search sowie YouTube zu nutzen.

Das Klagepatent ist Teil eines von der XXX (im Folgenden: XXX), XXX aufgelegten Lizenzierungsprogramms für Patente, die als wesentlich für die Implementierung des AAC-Standards erachtet werden. Der Pool fasst mehr als 3.600 Patente. Die XXX fungiert bei dem Abschluss von Lizenzverträgen mit Dritten als Verwalterin des AAC-Lizenzierungsprogramms (im Folgenden auch: AAC-Pool) und als nicht-ausschließliche Vertreterin der Patentinhaber, deren Patente in dem AAC-Pool eingelagert sind. Neben der Lizenzierung über den AAC-Pool können weiterhin auch die einzelnen Pool-Patentinhaber, zu denen neben der Klägerin unter anderem auch XXX gehören (vgl. zu den Pool-Mitgliedern insgesamt die mit Anlage K1b vorgelegte Liste mit der Überschrift „AAC Licensors“), über bilaterale Vereinbarungen Lizenzen an ihren Patenten vergeben. 20

Der AAC-Pool verfügt über mehr als 800 Lizenznehmer, unter anderem XXX (eine Übersicht aller Lizenznehmer liegt als Anlage K1b dort die Liste mit der Überschrift „AAC Licensees“ vor). Die Lizenzierung der AAC-Pool Patente erfolgt über einen Standardlizenzvertrag, in dem die Lizenzgebühren ausweislich der Veröffentlichung auf der Internetseite der XXX wie folgt geregelt sind (vgl. screenshot Anlage K1b dort überschrieben mit „AAC License Fees“): 21

XXX 22

Daneben besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, mit der Klägerin eine bilaterale Vereinbarung über eine Lizenznahme an ihren AAC-relevanten Patenten zu treffen. 23

Auch andere Lizenzgeber vergeben Lizenzen auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen, so besteht beispielsweise zwischen XXX und der innerhalb des Konzerns der Beklagten für die TV-Sparte verantwortlichen Gesellschaft (XXX) eine solche Vereinbarung. 24

Die Beklagte zu 2) ist eine Tochtergesellschaft der XXX, die wiederum ein Tochterunternehmen der XXX, (vormals firmierend unter: XXX) ist. Die Beklagte zu 2) betreibt die deutschsprachige Webseite der Marke XXX (http://www.XXX), über die Smartphones und Tablets für deutsche Kunden beworben werden, darunter das Smartphone „XXX“ oder das Tablet „XXX“. Die Internetseite verlinkt zu Online-Händlern wie zum Beispiel Amazon, bei denen die Kunden die Geräte unmittelbar erwerben können. 25

Weiterhin liefert die Beklagte zu 2) Smartphones der Marke XXX in die Bundesrepublik Deutschland, darunter das Smartphone mit der Bezeichnung „XXX“. Schließlich ist die Beklagte zu 2) auch für die Website www. XXX verantwortlich, auf der Smartphones der Marke X beworben werden, die die XXX in die Bundesrepublik Deutschland liefert. Auf der Website werden Einzelhändler benannt, bei denen die Geräte bestellt werden können. Ebenso wird, wenn ein Kunde ein Gerät ausgewählt hat, über den Button „Jetzt kaufen“ angezeigt, wo dieses erworben werden kann. Über weitere Links kann der Kunde unmittelbar auf die Seiten der entsprechenden Händler gelangen. 26

Die Beklagte zu 1) ist eine Tochtergesellschaft der Beklagten zu 2) (Die zuvor genannte „XXX“ wird nachfolgend – wenn auch bezogen auf die Beklagten zu 1) und zu 2) etwas verkürzt – als „Muttergesellschaft“ bezeichnet.). Die Beklagte zu 1) betreibt den deutschen Facebook-Auftritt der Marke XXX (https://www. XXX, auf dem auch das Smartphone „XXX“ oder das Tablet „XXX“ dargestellt werden. Es findet sich auch ein Link zur Website der Marke XXX der Beklagten zu 2). Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um ein Unternehmen, das sich auf lokale Marketingunterstützungsmaßnahmen für die Marken des XXX Konzerns beschränkt und in den Vertrieb von Smartphones und Tablets der Marke XXX in der Bundesrepublik Deutschland ansonsten nicht involviert ist. 27

28

Im Juli 2005 hatte die für Lizenzierungsfragen im Bereich „Smartphone“ zuständige Muttergesellschaft bereits eine AAC-Pool-Lizenz in Form des damals geltenden Standardlizenzvertrags erworben. Dieser Vertrag wurde jedoch von XXX mit Schreiben vom 02.03.2007 (Anlage K-Kart7) vorzeitig beendet.

Ob und in welchem Umfang dann weiterhin Gespräche zwischen XXX und der Klägerin stattfanden, ist zwischen den Parteien streitig. Unstreitig ist, dass jedenfalls zwischen der Klägerin bzw. XXX und den Beklagten persönlich bis in das Jahr 2020 hinein kein Kontakt im Hinblick auf eine Lizenznahme stattfand. 29

Nach Klagerhebung wandte sich die Muttergesellschaft mit Schreiben vom 25.03.2020 (Anlage K-Kart 12) an die Klägerin und erklärte, dass XXX bereit sei, von der Klägerin eine Lizenz zu FRAND Bedingungen zu nehmen. Diesem Schreiben folgten zwei weitere Schreiben vom 26.05.2020 und vom 09.07.2020, in denen die Muttergesellschaft erneut zur Abgabe eines bilateralen Angebots aufforderte. 30

Die Klägerin antwortete mit Schreiben vom 14.07.2020 (Anlage B21; deutsche Übersetzung: Anlage B21a). Hierin äußerte sie Zweifel an der Lizenzbereitschaft von XXX und verwies auf eine Lizenznahme über den AAC-Pool. Weiter teilte die Klägerin mit, dass sie keinen Anlass sehe, XXX ein bilaterales Angebot zu unterbreiten und in diesem Zusammenhang Kopien bereits abgeschlossener Lizenzverträge vorzulegen. 31

Mit Schreiben vom 17.08.2020 (Anlage B22; deutsche Übersetzung: Anlage B22a) kündigte XXX an, XXX im Hinblick auf die Poollizenz anzusprechen, hielt im Übrigen aber daran fest, dass ein bilaterales Vertragsangebot von der Klägerin erwünscht ist. XXX äußerte in diesen Zusammenhang zudem Bedenken im Hinblick auf ein diskriminierungsfreies Verhalten der Klägerin wegen der Vergabe bilateraler Lizenzen an ihrem Portfolio. Wegen des weiteren Inhalts wird auf das Schreiben verwiesen. Mit Schreiben vom selben Tag (liegt nicht vor) wandte XXX sich an XXX und verlangte nach zusätzlichen Informationen. XXX meldete sich daraufhin mit Schreiben vom 26.08.2020 (Anlage K-Kart11). 32

Die Klägerin teilte in einem Schreiben vom 05.10.2020 (Anlage B23; deutsche Übersetzung: Anlage B23a) mit, dass sie in der Möglichkeit zur Poollizenznahme ein im Sinne der FRAND-Bedingungen hinreichendes Angebot erblicke. Mit Schreiben vom 03.11.2020 (Anlage B24; deutsche Übersetzung: Anlage B24a), auf das wegen seines weiteren Inhalts Bezug genommen wird, teilte XXX erneut mit, zur Lizenznahme bereit zu sein, begehrte aber weiterhin ein bilaterales Angebot von der Klägerin. 33

Zuletzt verlangten die Beklagten mit E-Mail vom 15.03.2021 (Anlage B27) die Vertragsofferte für ein bilaterales Angebot, was die Klägerin ihrerseits mit E-Mail vom 18.03.2021 (Anlage B28) ablehnte. 34

Die Muttergesellschaft unterbreitete mit E-Mail vom 01.04.2021 der Klägerin ein als Anlage B29 vorgelegtes Gegenangebot, auf das wegen seines Inhalts Bezug genommen wird. Die Klägerin lehnte die Annahme in der mündlichen Verhandlung vom 09.04.2021 ab (vgl. Protokoll der Sitzung vom 09.04.2021, S. 2, letzter Abs., Bl. 413 GA). Eine Sicherheit leisteten die Beklagten daraufhin nicht. 35

Vor der entscheidenden Kammer sind auch von der Pool-Patentinhaberin „XXX“ gegen die Beklagten des hiesigen Verfahrens eingeleitete Verletzungsverfahren (Az.: XXX, XXX und XXX) anhängig. Die XXX erhob als Inhaberin von AAC-Pool-Patenten gegen die Beklagten Zahlungsklage aus zwei abgelaufenen Patenten vor dem Landgericht Mannheim. Eines der 36

beiden Verfahren wurde zugunsten der dortigen Klägerin beschieden, das Berufungsverfahren ist vor dem Oberlandesgericht Mannheim anhängig. Das andere Verfahren wurde bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt.

Die Klägerin wendet sich gegen Angebot und Vertrieb sämtlicher Mobiltelefone und Tablets durch die Beklagten, die vom Profil HE AAC v2 des AAC-Standards Gebrauch machen (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform), darunter die Smartphones „XXX“ oder „XXX“ oder das Tablet „XXX“. 37

Sie ist der Ansicht, dass ein Decodierer, der das Profil HE AAC v2, insbesondere das Parametric Stereo Tool, des AAC-Audiostandards implementiert habe und mit dem Standard kompatibel sei, zwangsläufig zur Anwendung des mit dem Klagepatentanspruch 1 geschützten Verfahren geeignet sei bzw. die Lehre des Klagepatentanspruchs 7 verwirkliche. Bei der angegriffenen Ausführungsform handele es sich um solche Decodiergeräte, die tatsächlich das Parametric Stereo Tool des Profils HE AAC v2 AAC-Audiostandards, verwendeten und insofern das Klagepatent verletzten. Insbesondere setze der Standard und damit auch die angegriffene Ausführungsform den Erhalt und die Verwendung eines Korrelationsparameters im Sinne des Klagepatents voraus, nämlich den ICC-Wert gemäß dem Standard. Dass es sich dabei nicht um den Maximalwert der Kreuzkorrelationsfunktion handele, sei unbeachtlich. Die Kompatibilität der angegriffenen Ausführungsform mit dem Standard ergebe sich aus der „Compatibility Definition“, also den Kompatibilitätserfordernissen, die das Unternehmen Google für das Betriebssystem Android in der Version 7.0 aufgestellt habe. Demnach setze die Verwendung dieses Betriebssystems, das von der angegriffenen Ausführungsform verwendet werde, die Unterstützung des Standards, insbesondere des HE AAC v2-Profils voraus. Die Verletzung werde ferner durch die von ihr durchgeführten Tests an einem von ihr erworbenen Smartphone der Beklagten nachgewiesen. 38

Die Beklagten seien auch passivlegitimiert. Die Beklagte zu 2) vertreibe die angegriffene Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland, wobei sie auch Besitz und Eigentum habe bzw. ausübe. Die Beklagte zu 1) stelle sich selbst als lokales Marketingunternehmen dar, dass die Vertriebstätigkeiten anderer konzernangehöriger Gesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland unterstütze. Sie wirke daher willentlich und wissentlich am Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform im Inland mit und müsse sich daher Besitz und Eigentum im Inland zurechnen lassen. 39

Die Beklagten könnten sich nicht mit Erfolg auf den Einwand der Erschöpfung berufen. Zwar habe XXX mit XXX einen Lizenzvertrag geschlossen, mit dem auch Nutzungsrechte an AAC-relevanten Patenten eingeräumt würden. Das Android-Betriebssystem sei jedoch kein unter diesem Lizenzvertrag lizenziertes Produkt, für das auch keine Lizenzgebühr gezahlt werde. Lizenziert seien bestimmte eigene Produkte von XXX wie zum Beispiel Mobiltelefone, Streaming-Geräte und dergleichen.Auch die von den Beklagten erhobene Einrede der Verjährung habe keinen Erfolg, da die Beklagten schon nicht aufzeigten, dass sie – die Klägerin – Kenntnis von den Beklagten als patentverletzende Personen gehabt habe. 40

Des Weiteren stünden ihr, der Klägerin, die geltend gemachten Ansprüche auch im Hinblick auf die Standardessentialität des Klagepatents zu. Der von den Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greife nicht durch. 41

Das Klagepatent vermittle ihr schon keine marktbeherrschende Stellung. An einer solchen fehle es jedenfalls, weil die Beklagten entweder auf alternative Betriebssysteme ausweichen oder ein eigenes Betriebssystem entwickeln könnten, ohne den AAC-Standard zu 42

implementieren. Auch auf diese Weise könne ein wettbewerbsfähiges Produkt angeboten werden.

Zudem ist die Klägerin der Ansicht, auch dann, wenn sie eine marktbeherrschende Stellung innehabe, seien die Grundsätze der EUGH-Rechtsprechung in der Rechtssache HUAWEI ./. ZTE (Urt. v. 16.0.72015 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 15.12.2015, Az.: C-170/13, GRUR 2015, 764; im Folgenden: EuGH-Rechtsprechung oder EuGH-Urteil) hier nicht anwendbar. Bei dem AAC-Standard handele es sich nicht um einen Mobilfunkstandard, sondern um eine technische Spezifikation, die einen de-facto Standard etabliere, der nach den von dem BGH in der „Orange-Book-Standard“ Entscheidung (BGH, NJW-RR 2009, 1047) entwickelten Grundsätzen zu beurteilen sei. Die Beklagten seien den sie danach treffenden kartellrechtlichen Pflichten nicht nachgekommen. 43

Aber auch bei Orientierung an der EuGH-Rechtsprechung nutze sie, die Klägerin, eine marktbeherrschende Stellung nicht durch die Geltendmachung der auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichteten Ansprüche aus. 44

Die Beklagten seien schon nicht als lizenzwillig zu erachten. 45

In diesem Zusammenhang behauptet die Klägerin, was die Beklagten mit Nichtwissen bestreiten, die Kommunikation habe sich im Anschluss an die Vertragsbeendigung mit der Muttergesellschaft ab dem Jahre 2016 wie folgt dargestellt: 46

Am 03.02.2016 habe XXX ein weiteres Mal den Entwurf eines Standardlizenzvertrags übersandt. Auf das hier in Bezug genommene Schreiben (Anlage K-Kart8) wird verwiesen. Anfang März 2016 sei es zu einem persönlichen Treffen zwischen XXX und XXX gekommen, in dessen Rahmen XXX zum einen die Frage nach Claim Charts und zum anderen die Erschöpfungsfrage mit Blick auf „XXX“ und „XXX“ aufgeworfen habe. Mit Schreiben vom 23.03.2016 (Anlage K-Kart9) habe XXX unter anderem mitgeteilt, dass weder „XXX“ noch „XXX“ Lizenznehmer seien und XXX nicht im Hinblick auf Produkte Dritter lizenziert sei. Wegen Fragen zur Standardessentialität sei XXX an die Pool-Lizenzgeber verwiesen worden. 47

Mit Schreiben vom 12.12.2016 (Anlage K1c) habe sie, die Klägerin, sich an die Muttergesellschaft gewandt. Dem Schreiben sei eine Liste der für den AAC-Standard relevanten Patente der Klägerin, die auch das Klagepatent enthalten habe, sowie Claim Charts der wichtigsten Patentfamilien der für den AAC-Standard wesentlichen Patente der Klägerin beigefügt gewesen. Eine Reaktion seitens XXX sei nicht erfolgt. 48

Am 13.04.2017 (Anlage K-Kart 10) habe XXX erneut Informationen zur Lizenznahme am AAC-Pool übersandt – auf das näher bezeichnete Schreiben wird insoweit Bezug genommen – und einen aktuellen Standardlizenzvertrag beigefügt. 49

Weitere Anfragen von XXX in der Folgezeit seien unbeantwortet geblieben. 50

Nach alledem finde die fehlende Lizenzbereitschaft bereits darin einen Ausdruck, dass die Muttergesellschaft sich inhaltlich nicht mit dem ihr vorliegenden Pool-Lizenzangebot von XXX befasse. Aber auch an der Bereitschaft zum Abschluss einer bilateralen Lizenz fehle es. Die Muttergesellschaft insistiere nur deshalb auf einem bilateralen Angebot, um so ein Verteidigungsargument im Rahmen des hiesigen Verfahrens zu schaffen. 51

Unbeschadet dessen sei sie, die Klägerin, ihren Verpflichtungen zur Unterbreitung eines FRAND-gemäßen Angebots dadurch nachgekommen, dass der Muttergesellschaft die 52

Lizenznahme in Form des FRAND-gemäßen Standardlizenzvertrags angeboten worden sei. Die Muttergesellschaft könne darüber hinaus das Angebot einer bilateralen Vereinbarung nicht einfordern. Nach der EuGH-Rechtsprechung müsse der SEP-Inhaber ein FRAND-Lizenzangebot unterbreiten, ein Anspruch auf mehrere Lizenzangebote bestehe hingegen nicht.

Es sei zudem kein Interesse der Muttergesellschaft an einer bilateralen Lizenz erkennbar. 53

Die Klägerin beantragt, 54

1. die Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, 55

Smartphones und Tablets zur Durchführung eines Verfahrens zum Synthetisieren eines ersten und zweiten Audio-Ausgangssignals von einem Eingangssignal 56

zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn das Verfahren die nachfolgenden Schritte umfasst: 57

- das Filtern des Eingangssignals zum Erzeugen eines gefilterten Signals, 58

- das Erhalten eines Korrelationsparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal, 59

- das Erhalten eines Pegelparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal, 60

- das Transformieren des Eingangssignals und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal, wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter und dem Pegelparameter abhängig ist, 61

insbesondere wenn 62

der Matrixvorgang eine übliche Rotation um einen vorbestimmten Winkel des ersten und zweiten Ausgangssignals in einem Raum umfasst, der von dem Eingangssignal und dem gefilterten Eingangssignal umfasst wird, und wenn der vorbestimmte Winkel von dem Pegel-Parameter abhängig ist; 63

2. die Beklagten zu verurteilen, es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen 64

Anordnungen zum Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Audio-Ausgangssignals von einem Eingangssignal 65

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, 66

67

wenn die Anordnungen Folgendes umfassen:

- Filtermittel zum Filtern des Eingangssignals zum Erzeugen eines gefilterten Signals, 68

- Mittel zum Erhalten eines Korrelationsparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal, 69

- Mittel zum Erhalten eines Pegelparameters, der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal, 70

- Mittel zum Transformieren des Eingangssignals und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal, wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter und dem Pegelparameter abhängig ist; 71

3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung – hinsichtlich der Angaben a) und b) unter Vorlage von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheinen, weiter hilfsweise Quittungen in Kopie, wobei Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können – darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie seit dem 30. Oktober 2009 Mittel gemäß Ziffer 1. zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland angeboten oder geliefert haben, 72

und zwar unter Angabe 73

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, 74

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, 75

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, 76

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen, 77

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, 78

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist; 79

4. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung – hinsichtlich der Angaben a) und b) unter Vorlage von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheinen, 80

weiter hilfsweise Quittungen in Kopie, wobei Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können – darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie seit dem 30. Oktober 2009 Anordnungen gemäß Ziffer 2. in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

und zwar unter Angabe 81

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, 82

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, 83

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, 84

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen, 85

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, 86

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist; 87

5. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1. und 2. bezeichneten Handlungen seit dem 30. Oktober 2009 entstanden ist und noch entstehen wird; 88

6. die Beklagten zu verurteilen, die unter Ziffer 2. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 30. Oktober 2009 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents XXX (deutscher Teil des XXX) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst; 89

7. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, in Ziffer 2. bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu 90

vernichten oder nach Ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben.

Die Beklagten beantragen, 91

die Klage abzuweisen; 92

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung des gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen, 93

weiter hilfsweise ihr im Unterliegensfall zu gestatten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden. 94

Die Beklagten bestreiten eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform mit Nichtwissen. Sie tragen vor, dass der Standard insgesamt nicht zwingend sei und sich eine Implementierung desselben auch nicht aus der „Compatibility Definition“ für das Betriebssystem Android ergebe. Außerdem setze der Standard die erfindungsgemäße Lehre nicht voraus, weil es insbesondere an einem Korrelationsparameter im Sinne des Klagepatents fehle. Zwar enthalte der Standard einen Korrelationsparameter, doch dieser bestehe nicht aus dem Maximalwert der Kreuzkorrelationsfunktion, wie das Klagepatent es erfordere. Daneben seien die von der Klägerin durchgeführten Tests ebenfalls nicht geeignet, um eine Verletzung nachzuweisen. 95

Die Beklagten sind weiter der Ansicht, dass sie nicht passivlegitimiert seien. Die Beklagte zu 1) biete die angegriffenen Produkte weder an, noch vertreibe sie sie, weil es sich bei ihr um eine rein nationale Tochtergesellschaft des XXX Konzerns handele, die auf lokale Marketingunterstützungsmaßnahmen für die Marken des XXX Konzerns beschränkt sei. Die Abbildung von Smartphones und Tablets in dem Facebook-Auftritt erfolge nicht mit Vertriebsabsicht, da sie dort nicht erworben werden können. Auch auf der verlinkten Internetseite der Marke XXX bestehe keine unmittelbare Erwerbsmöglichkeit. Mangels eines eigenen Vertriebs fehle es an den Voraussetzungen für einen Rückrufanspruch und einen Vernichtungsanspruch, zumal die Beklagte zu 1) weder Eigentum noch Besitz an der angegriffenen Ausführungsform habe. 96

Was die Beklagte zu 2) angehe, lasse der von der Klägerin vorgelegte Auszug aus dem Internetauftritt der Beklagten zu 2) eine Patentverletzung nicht erkennen. Hinsichtlich des abgebildeten Smartphones „XXX“ werde eine Patentverletzung mit Nichtwissen bestritten. Aus der Produktabbildung seien die Merkmale der Patentansprüche jedenfalls nicht ersichtlich. Hinsichtlich des Rückrufanspruchs fehle es auch hier an der Darlegung einer Vertriebshandlung. 97

Weiterhin berufen sich die Beklagten auf den Grundsatz der Erschöpfung. Selbst wenn die Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur Benutzung der Lehre des Klagepatents gegeben wäre, wäre dies darauf zurückzuführen, dass bereits das Betriebssystem Android die Funktionalität zur Durchführung des Verfahrens bereitstelle. Das Betriebssystem als Mittel zur Benutzung der patentgemäßen Lehre sei aber aufgrund eines Lizenzvertrages zwischen XXX und XXX und daher mit Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents in den Verkehr gebracht worden. 98

Die Beklagten halten im Übrigen die geltend gemachten Rückruf- und Vernichtungsansprüche für unverhältnismäßig. Die Durchsetzung dieser Ansprüche würde die angegriffene Ausführungsform vollständig vom Markt entfernen, obwohl die Lehre des 99

Klagepatents nur einen geringen Anteil am Funktionsumfang der angegriffenen Ausführungsform habe und diese ganz überwiegend auf eine Benutzung als Kommunikationsmittel außerhalb des Klagepatents ausgelegt sei. Als milderes Mittel statt der Vernichtung sei den Beklagten allenfalls die Beseitigung einer etwaigen Unterstützung des patentgemäßen Verfahrens durch ein Softwareupdate aufzugeben. Zudem sei ein Rückruf aller seit dem 30. Oktober 2009 auf den Markt gebrachten patentverletzenden Erzeugnisse unverhältnismäßig, weil keine realistische Aussicht bestehe, dass sich entsprechende Erzeugnisse noch in den Vertriebswegen befänden. Aktuelle Modelle von Mobilfunkgeräten wiesen eine durchschnittliche Verkaufsdauer von zwei bis vier Jahren auf. Die Beklagten erheben die Einrede der Verjährung. Ansprüche aufgrund von Handlungen der Beklagten in den Jahren 2015 oder früher seien verjährt. Sie behaupten, die Klägerin habe bereits über den gesamten Zeitraum die erforderliche Kenntnis gehabt. Sie – die Klägerin – trage selbst vor, dass die Muttergesellschaft bereits im Jahr 2005 eine Lizenz am Klagepatent genommen habe, die im Jahr 2006 beendet worden sei. Damit habe die Klägerin bereits im Jahr 2006 das Wissen gehabe, dass die Produkte aus dem XXX-Konzern angeblich Gebrauch von der Lehre des Klagepatents machten. Jedenfalls müsse man der Klägerin das Wissen von XXX zurechnen. Zudem sei es öffentlich und daher auch der Klägerin bekannt, dass es sich bei dem XXX-Konzern um ein weltweit operierendes Technologieunternehmen handele. Es reiche aus, wenn der Gläubiger in der Lage sei, ohne größere Mühen und Kosten die Informationen über den Schuldner zu erlangen. Dazu behaupten die Beklagten, es sei ohne weiteres möglich gewesen, über Internetrecherche oder durch Blick auf die Produktverpackung festzustellen, dass die Beklagten zu 1) und 2) auch schon im Jahr 2015 in der Bundesrepublik Deutschland Vertriebs- oder Marketingtätigkeiten entwickelten. Unter anderem seien sie, jedenfalls die französische Gesellschaft, auf der IFA tätig gewesen.

Die Beklagten erheben zudem den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. 100

In diesem Zusammenhang behaupten sie, für den Fall der Standardessentialität vermittle das Klagepatent der Klägerin, eine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für Smartphones und Tablet PCs. Denn ohne die Benutzung des Klagepatents könne ein wettbewerbsfähiges Gerät nicht in den Verkehr gebracht werden. 101

Dieser Umstand folge zum einen daraus, dass der Einsatz nutzerseitig stark nachgefragter mobiler Streamingdienste (bspw.: Netflix, Pandora, YouTube, Spotify) nur möglich sei, wenn der AAC-Standard implementiert sei, und zum anderen aus der Erforderlichkeit für den Einsatz des Betriebssystems „Android“, weil andernfalls Apps wie Google Search, YouTube, Google Maps und den Google Play Store nutzen zu können. Android-Smartphones, bei denen die Google-Dienste mangels AAC-Standard fehlen, könnten allenfalls auf einem Nischenmarkt vertrieben werden. 102

Es sei den Herstellern auch nicht möglich, auf ein alternatives Betriebssystem auszuweichen, da auf dem Markt lediglich das Android-System von Google sowie das iOS-System von Apple, an dem Lizenzen unstreitig nicht genommen werden können, vorherrschen. Nutzerseitig stark nachgefragte Applikationen würden zudem nur für Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Ein wettbewerbsfähiges Produkt könne durch einen Rückgriff auf alternative Betriebssysteme oder die Entwicklung eines eigenen Betriebssystems nicht angeboten werden, vielmehr könne mit diesen lediglich ein Nischenmarkt erschlossen werden. 103

Die Klägerin sei ihren Verpflichtungen nach der EuGH-Rechtsprechung, die auch dann Anwendung finde, wenn es sich bei dem streitgegenständlichen Standard um einen sog. „de-facto Standard“ handele, nicht nachgekommen. 104

Sie, die Beklagten bzw. ihre Muttergesellschaft, seien lizenzbereit, wie ihren fortwährenden ausdrücklichen Lizenzbereitschaftserklärungen zu entnehmen sei. 105

Die Klägerin sei verpflichtet, eine bilaterale Vereinbarung zur Lizenznahme zu unterbreiten. Dies ergebe sich bereits aus Diskriminierungsgesichtspunkten, weil die Klägerin ihre für den AAC-Standard als wesentlich erachteten Patente bereits über bilaterale Vereinbarungen lizenziert habe bzw. bilaterale Lizenzangebote unterbreite. Eine entsprechende Verpflichtung ergebe sich weiter aber auch aus der gegenüber ISO/IEC abgegebenen Erklärung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. 106

Im Zusammenhang mit ihrem bilateralen Angebot müsse die Klägerin dann auch sämtliche bereits existierenden vergleichbaren Vereinbarungen mit Dritten vorlegen. 107

Schließlich werde sich das Klagepatent auch nicht als rechtsbeständig erweisen. Der Gegenstand der erfindungsgemäßen Lehre werde im Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen und sei zudem nicht erfinderisch. 108

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist weitgehend begründet. 109

A

Die Klägerin hat gegen die Beklagten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf (nur Beklagte zu 2) sowie Schadensersatz dem Grunde nach aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB. Ein Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG besteht nicht. 110

I. 111

Die dem Klagepatent zu Grunde liegende Erfindung betrifft die Synthese zweier Ausgangssignale auf der Grundlage eines Eingangssignals, Abs. [0001] des Klagepatents (alle folgenden, nicht näher bezeichneten Absätze sind solche des Klagepatents). 112

Das Klagepatent erläutert, dass parametrische Audiocodierer immer interessanter geworden seien. Denn es habe sich herausgestellt, dass die Übertragung von Parametern, die Audiosignale beschreiben, nur wenig Übertragungskapazität erfordere. Auf diese Art und Weise werde eine Decodierung an dem empfangenden Ende ermöglicht, was zu einem Audiosignal führe, das in der Wahrnehmung nicht wesentlich von dem ursprünglichen Signal abweiche. Da nur ein einziger Audiokanal in Kombination mit einem Parameterbitstrom übertragen werde, der die räumlichen Eigenschaften des Stereosignals beschreibe, könnten Bitraten eingespart werden. Ferner werde dadurch ermöglicht, dass ein Decoder die räumlichen Eigenschaften des Stereosignals reproduziere, Absatz [0002]. 113

Aus dem Stand der Technik sei der Artikel "Efficient representation of special audio using perceptual parameterization" (Faller und Baumgarte, "IEEE Workshop on applications of signal processing to audio and acoustics", 21. Oktober 2001) bekannt, der eine Darstellung 114

räumlichen Audios beschreibe, das ein monaurales Summensignal und daneben eine interaurale Pegeldifferenz sowie interaurale Zeitdifferenz in jedem entscheidenden Band aufweise. Zum Synthetisieren des binauralen Signals würden dann die Pegeldifferenzen und die Zeitdifferenzen auf die Spektralkoeffizienten des monauralen Signals angewandt, Absatz [0003].

Bei einem der oben genannten räumlichen Parameter, der für die Codierung eines Stereosignals mit einem Links-Kanal (im Folgenden: L oder L-Kanal) und einem Rechts-Kanal (im Folgenden: R oder R-Kanal) von Bedeutung sei, handele es sich um die sogenannte Interkanal-Kreuzkorrelation zwischen diesen beiden Kanälen. In vielen Systemen sei dies einer der Signalparameter, die von einem Codierer analysiert werden. Die ermittelte Kreuzkorrelation werde danach zusammen mit einem Monosignal von dem Codierer zu einem entsprechenden Decoder übertragen, Absatz [0004]. Daraufhin würden beim Decoder zwei Ausgangssignale rekonstruiert, die die gewünschte Kreuzkorrelation hätten, Absatz [0005]. 115

Das Klagepatent erläutert, dass mehrere Verfahren zum Dekorrelieren von Signalen bekannt seien. So zeige die Figur 1 des Klagepatents, die im Folgenden wiedergegeben ist, den sogenannten Lauridsen-Dekorrelator: 116

117

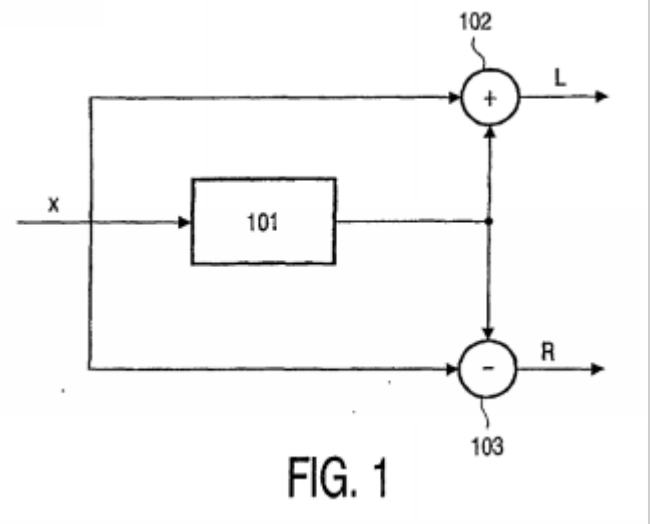

FIG. 1

Der Lauridsen-Dekorrelator umfasse ein sogenanntes Allpass-Filter, das beispielsweise eine verzögerte Version der Wellenform des Eingangssignals x erzeuge und gegebenenfalls verstärke. Eine Addition des Ausgangssignals Hx des Filters zu dem Eingangssignal führe zum L-Kanal und eine Subtraktion des Ausgangssignals Hx vom Eingangssignal führe zum R-Kanal, Absatz [0006]. 118

Nach der Klagepatentbeschreibung sei der Lauridsen-Dekorrelator brauchbar, so lange sich die beiden Ausgangssignale einander im Pegel sehr ähnlich seien oder sogar entsprechen. Parametrische Audiocodierer würden den Ausgangssignalen aber auch Pegeldifferenzen zufügen (sogenanntes „Amplituden-Panning“). Insofern bringe der Lauridsen-Dekorrelator bei großen Pegeldifferenzen das Problem mit sich, dass die wahrgenommene Qualität der erzeugten Signale abnehme, Absatz [0007]. 119

Das Klagepatent hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses und andere Probleme zu lösen, Absatz [0008]. 120

121

Dazu schlägt das Klagepatent mit dem von der Klägerin geltend gemachten Anspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1a Verfahren zum Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Ausgangssignals (L, R) von einem Eingangssignal (X), wobei das Verfahren die nachfolgenden Verfahrensschritte umfasst: 122

1b das Filtern des Eingangssignals (X) zum Erzeugen eines gefilterten Signals, 123

1c das Erhalten eines Korrelationsparameters (r), der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R), 124

1d das Erhalten eines Pegelparameters (c), der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R), 125

1e das Transformieren des Eingangssignals (X) und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal (L, R), wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter (r) und dem Pegelparameter (c) abhängig ist. 126

Daneben schlägt das Klagepatent mit dem Anspruch 7 eine Anordnung zum Synthetisieren von Ausgangssignalen aus einem Eingangssignal mit nachstehenden Merkmalen vor: 127

7a Anordnung zum Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Audio-Ausgangssignals (L, R) von einem Eingangssignal (X), wobei diese Anordnung Folgendes umfasst: 128

7b Filtermittel (201) zum Filtern des Eingangssignals (X) zum Erzeugen eines gefilterten Signals, 129

7c Mittel (202) zum Erhalten eines Korrelationsparameters (r), der indikativ ist für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R), 130

7d Mittel (202) zum Erhalten eines Pegelparameters (c), der indikativ ist für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R), 131

7e Mittel (203) zum Transformieren des Eingangssignals (X) und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal (L, R), wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter (r) und dem Pegelparameter (c) abhängig ist. 132

Mit der Durchführung eines Matrixvorgangs, der von der gewünschten Korrelation und der gewünschten Pegeldifferenz abhängig sei, werde nach dem Klagepatent eine wesentliche Zunahme der wahrnehmbaren Qualität der Ausgangssignale eines parametrischen Decoders erreicht, Absatz [0009]. 133

II. 134

Das erfindungsgemäße Verfahren nach dem Patentanspruch 1 löst das im Stand der Technik bekannte Problem dadurch, dass es einen Matrixvorgang vorsieht, der nicht nur vom Korrelationsparameter, sondern auch vom Pegelparameter abhängig ist. 135

1.

Merkmal 1b sieht die Erzeugung eines gefilterten Signals vor, indem das Eingangssignal (X) gefiltert wird. Dieser Vorgang ist aus dem Stand der Technik bekannt. Beide Signale, das Eingangssignal (X) und das gefilterte Signal, sind dann Gegenstand des Matrixvorgangs, bei dem aus den beiden Signalen die beiden Ausgangssignale errechnet werden. 136

2.

Merkmal 1c sieht das Erhalten eines sogenannten Korrelationsparameters vor, der indikativ für eine gewünschte Korrelation zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R) ist. 137

a)

Bei dem Korrelationsparameter handelt es sich um einen Wert für die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit der beiden Ausgangssignale (L, R). Dass der Parameter „indikativ“ (im englischen Wortlaut „*indicative of*“) sein muss, heißt, dass dieser die gewünschte Korrelation erkennen lassen bzw. aufzeigen muss. 138

Der Korrelationsparameter (r) bildet neben dem in Merkmal 1d genannten Pegelparameter (c) einen der maßgeblichen Parameter, die bei dem Synthetisieren eines ersten und eines zweiten Ausgangssignals auf der Grundlage eines eingehenden Eingangssignals zur Anwendung kommen. Dazu fließen die beiden Parameter in den in Merkmal 1e näher beschriebenen Matrixvorgang ein. 139

Daneben existieren weitere Parameter, die bei der Signalsynthese relevant sein können, aber für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre keine Rolle spielen. 140

Soweit der Parameter teilweise mit (r) und teilweise mit (?) (griechisch „tau“) bezeichnet wird, handelt es sich lediglich um eine sprachliche Ungenauigkeit. Ähnliches gilt für die Verwendung des Buchstabens ? für die Korrelation im Rahmen der Beschreibung. Zum Zweck der Übersichtlichkeit wird vorliegend einheitlich die Schreibweise (r) verwendet. 141

b)

Der Korrelationsparameter beschreibt das Maß der Interkanal-Korrelation und wird als aus dem Stand der Technik bekannt beschrieben. In Absatz [0004] heißt es insofern, dass es sich dabei um einen räumlichen Parameter handele, der in vielen Systemen einen der vom Codierer analysierten Signalparameter darstelle und zusammen mit dem Mono-Signal an einen Decoder übertragen werde. Sodann würden bei dem Decoder zwei Ausgangssignale rekonstruiert, die die gewünschte Kreuzkorrelation aufweisen würden, Absatz [0005]. Beispielhaft für das Dekorrelieren von Signalen beschreibt Absatz [0006] sodann den aus dem Stand der Technik bekannten Lauridsen-Dekorrelator, der schematisch in der Figur 1 gezeigt wird. 142

c)

Aus dem Wortlaut des Klagepatentanspruchs in Verbindung mit der Beschreibung ergibt sich, dass der Korrelationsparameter anzeigt, wie ähnlich oder unähnlich sich die ausgegebenen Signale L und R sind, wobei die Ausgangssignale durch Vektoren und der Grad der Korrelation durch den Winkel ? entsprechend ?=cos(?) angegeben werden können. 143

Soweit die Beschreibung des Klagepatents den Parameter noch näher spezifiziert, geschieht dies entweder allein im Hinblick auf Merkmale, die erst in den Unteransprüchen genannt werden oder hinsichtlich bestimmter Ausführungsformen, so dass es sich damit um Einschränkungen handelt, die für die erfindungsgemäße Lehre in ihrer im Klagepatentanspruch 1 zum Ausdruck kommenden Form nicht relevant sind. 144

Das gilt vor allem, sofern die Beschreibung in Absatz [0044] erläutert, dass die Analyseschaltung die Verschiedenheit bzw. Gleichartigkeit und damit die Korrelation der Wellenformen analysiert, die nicht durch ITDen oder ILDen nachgewiesen werden können, die durch den maximalen Wert der Kreuzkorrelationsfunktion parametrisiert werden können. Die Abkürzung ITD steht dabei für die Zeit- bzw. Phasendifferenz (*interaural time difference* bzw. IPD für die *interaural phase difference*) und ILD steht für die Pegeldifferenz (*interaural level difference*). 145

Der zitierte Absatz vermag die Lehre des Klagepatentanspruchs auf einen Korrelationsparameter in Form des maximalen Wertes der Kreuzkorrelationsfunktion (vgl. auch Abs. [0046]) nicht zu beschränken. Der Maximalwert der Kreuzkorrelationsfunktion hat im Klagepatentanspruch keinen Niederschlag gefunden; es genügt vielmehr jeder Korrelationsparameter unabhängig davon, auf Grundlage welcher Korrelationsfunktion auch immer er gewonnen wurde, solange er nur indikativ für die (Un-)Ähnlichkeit der beiden Ausgangssignale L und R ist. 146

Der gesamte Abschnitt der Klagepatentbeschreibung ab Absatz [0038], in dem sich auch der zitierte Absatz [0044] findet, betrifft zudem nur eine bevorzugte Ausführungsform, die grundsätzlich nicht geeignet ist, den weiter gefassten Klagepatentanspruch 1 weiter zu beschränken. Dies ergibt sich aus Absatz [0038] und [0040], die sich lediglich auf „ein System zur Audiocodierung“ und auf die Verfahrensweise „in einer Ausführungsform“ beziehen. Darüber hinaus wird auch aus Absatz [0043], der neben der interauralen Pegeldifferenz (ILD) auch die interaurale Zeitdifferenz oder Phasendifferenz (ITD oder IPD) beschreibt, deutlich, dass es sich lediglich um ein Ausführungsbeispiel handelt. Denn die ITD bzw. IPD hat ebenfalls keinen Eingang in den Klagepatentanspruch gefunden. 147

Auch bei der gebotenen funktionalen Betrachtungsweise ist es nicht notwendig, das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion als Korrelationsparameter zu verwenden. Zwar ist die Lehre des Klagepatent darauf gerichtet, das im Stand der Technik herrschende Problem geringerer Qualität der erzeugten Signale bei großen Pegeldifferenzen zu lösen. Dafür ist die erfindungsgemäße Lehre aber schon nicht auf die Kreuzkorrelationsfunktion beschränkt. Zudem erfordert sie nicht die bestmögliche Lösung in Form des Maximums der Kreuzkorrelationsfunktion. Die Qualität der erzeugten Signale bei großen Pegeldifferenzen wird sich auch schon mit anderen Werten der Kreuzkorrelationsfunktion verbessern lassen, zumal dies vielleicht zugunsten anderer akustischer Parameter vorzugswürdig ist. 148

Soweit die Beklagten meinen, die Klägerin habe schriftsätzlich zugestanden, dass die Lehre des Klagepatentanspruchs 1 das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion betreffe, lässt sich 149

dies dem klägerischen Vortrag nicht entnehmen. Es wäre für die Auslegung des Klagepatentanspruchs, bei der es sich um eine Rechtsfrage handelt, ohnehin unbeachtlich.

3.

Merkmal 1d sieht das Erhalten eines sogenannten Pegelparameters vor, der indikativ für eine gewünschte Pegeldifferenz zwischen dem ersten und dem zweiten Ausgangssignal (L, R) ist. 150

a)

Dem Wortlaut nach handelt es sich bei dem Pegelparameter um eine Vorgabe hinsichtlich des Pegels und damit der Lautstärke bezogen auf die Ausgangssignale L und R. Wie bereits im Hinblick auf den Korrelationsparameter gilt auch hier, dass dieser Parameter für die gewünschte Pegeldifferenz indikativ sein und diese damit erkennen lassen bzw. aufzeigen muss. Der auch mit (c) bezeichnete Pegelparameter fließt neben dem Korrelationsparameter (r) in den in Merkmal 1e beschriebenen Matrixvorgang ein. 151

b)

Der Pegelparameter beschreibt das Maß der Lautstärkedifferenz zwischen den beiden Ausgangssignalen und wird als aus dem Stand der Technik bekannt beschrieben. So heißt es in Absatz [0007], dass parametrische Audiocodierer den Ausgangssignalen Pegeldifferenzen hinzufügten, was auch als „Amplituden-Panning“ bezeichnet werde. 152

Absatz [0042] beschreibt ferner, dass die interaurale Pegeldifferenz auch als ILD bezeichnet und durch die relativen Pegel der entsprechenden bandbegrenzten Signale – ausgehend von den zwei Eingängen – definiert werde. 153

4.

Das Merkmal 1e sieht ein Transformieren des Eingangssignals (X) und des gefilterten Signals durch einen Matrixvorgang zu dem ersten und zweiten Ausgangssignal (L, R) vor, wobei der Matrixvorgang von dem Korrelationsparameter (r) und dem Pegelparameter (c) abhängig ist. 154

a)

Der Begriff des Matrixvorgangs wird in Absatz [0017], der dem allgemeinen Teil der Patentbeschreibung angehört, definiert. Demnach bezieht sich der Ausdruck Matrixvorgang auf einen Vorgang, der ein Eingangssignal mit mehreren Kanälen in ein Ausgangssignal mit mehreren Kanälen transformiert, wobei die Anteile des Mehrkanal-Ausgangssignals lineare Kombinationen der Anteile des Mehrkanal-Eingangssignals sind. 155

Die Klagepatentbeschreibung erläutert den Matrixvorgang in Absatz [0023] beispielhaft anhand des in Figur 2 gezeigten Dekorrelators, der eine Schaltungsanordnung aufweist. Die 156

Schaltung ermittelt eine Mischmatrix M(?, ?), in die neben den beiden Parametern das empfangene Ausgangssignal x und das mittels eines Allpass-Filters gefilterte Signal H_*x in die Transformationsschaltung 203 einfließen. Im Einzelnen wird – um die gewünschten Ausgangssignale L und R zu erreichen – der Mischvorgang entsprechend der folgenden Gleichung durchgeführt (siehe Absatz [0023], Gleichung 1):

157

$$\begin{pmatrix} L \\ R \end{pmatrix} = M(\alpha, \beta) \cdot \begin{pmatrix} x \\ H \otimes x \end{pmatrix}$$

Werden die beiden Ausgangssignale als Vektoren dargestellt, kann eine Mischmatrix, die die Signale x und H_*x sowie den Korrelationsparameter (r) enthält, dargestellt werden wie folgt (siehe Absatz [0026], Gleichung 2): 158

159

$$M = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) & \sin(\alpha/2) \\ \cos(-\alpha/2) & \sin(-\alpha/2) \end{pmatrix}.$$

Eine Matrix, die daneben auch den Pegelparameter (c) berücksichtigt und darüber hinaus eine zusätzliche Rotation der Vektoren um den Winkel ? vorsieht, kann wie folgt aussehen (siehe Absatz [0032], Gleichung 4): 160

161

$$M = C \cdot \begin{pmatrix} \cos(\beta + \alpha/2) & \sin(\beta + \alpha/2) \\ \cos(\beta - \alpha/2) & \sin(\beta - \alpha/2) \end{pmatrix}.$$

mit einer Skalierungsmatrix C, die gewährleistet, dass die relative Pegeldifferenz zwischen den Ausgangssignalen dem Wert c entspricht (siehe Absatz [0033]). 162

Die Lehre des Klagepatents ist jedoch nicht auf eine Matrix mit den in der Beschreibung des Klagepatents wiedergegebenen Koeffizienten beschränkt. Das gilt für die Werte der Skalierungsmatrix C (siehe Absatz [0033]), aber auch für die weitere Drehung um den Winkel ?, der bevorzugt so gewählt werden soll, dass der Anteil des Eingangssignals in der Summe der beiden Ausgangssignale L und R maximal wird und der Betrag des gefilterten Signals minimal (siehe Absatz [0031] und Absatz [0041]). Die Drehung um den Winkel ? betrifft lediglich eine bevorzugte Ausführungsform, die Gegenstand von Unteranspruch 2 ist. 163

b)

Das Transformieren des Eingangssignals X und des gefilterten Signals in die beiden Ausgangssignale L und R durch einen Matrixvorgang in Abhängigkeit von dem Korrelationsparameter und dem Pegelparameter zeichnet die Lehre des Klagepatents gegenüber dem Stand der Technik aus. Mit dem Merkmale 1e wird das im Stand der Technik bestehende technische Problem der Qualitätsminderung bei großen Pegeldifferenzen, wenn nur die Kreuzkorrelation als Signalparameter verwendet wird, überwunden. Dies führt das Klagepatent anhand des Ausführungsbeispiels aus. 164

Demnach stellt die Arbeitsweise des im Stand der Technik bekannten Lauridsen-Dekorrelators, der in der Figur 1 des Klagepatents dargestellt ist, einen Sonderfall des Matrixvorgangs gemäß der Gleichung 2 165

166

$$M = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) & \sin(\alpha/2) \\ \cos(-\alpha/2) & \sin(-\alpha/2) \end{pmatrix}.$$

dar. Wird nämlich ? = 90° gesetzt, ergibt sich eine Matrix (3) mit 167

168

$$M = \sqrt{2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}},$$

dem gemäß Absatz [0028] des Klagepatents der Lauridsen-Dekorrelator entspricht. Es ist – wie in Absatz [0029] ausgeführt wird – unmittelbar einsichtig, dass, wenn nur im Linkskanal ein bestimmtes Signal vorhanden ist und die Korrelation der beiden Ausgangssignale Null ist, der Lauridsen-Dekorrelator keine optimale Lösung liefert, weil das Ausganssignal L auch einen Anteil des gefilterten Eingangssignals enthält. Durch die Abhängigkeit des Matrixvorgangs vom Korrelationsparameter und der Pegeldifferenz bietet die Lehre des Klagepatents nunmehr die Möglichkeit, das aus dem Stand der Technik bekannt Problem zu lösen. Dies kann insbesondere durch den im Ausführungsbeispiel des Klagepatents in Absatz [0034] vorgeschlagenen Matrixvorgang 169

170

$$\begin{pmatrix} L \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{c}{1+c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+c} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\beta+\alpha/2) & \sin(\beta+\alpha/2) \\ \cos(\beta-\alpha/2) & \sin(\beta-\alpha/2) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ H \otimes x \end{pmatrix}$$

erreicht werden, der zur Erhöhung des Anteils des Eingangssignals eine zusätzliche Drehung um den Winkel ? und eine Skalierungsmatrix C zur Gewährleistung der Pegeldifferenz vorsieht (siehe Absatz [0033]). Darauf ist die Lehre des Klagepatents jedoch nicht beschränkt; andere Matrixvorgänge sind denkbar und möglich. 171

III. 172

Hinsichtlich der Auslegung des Vorrichtungsanspruchs 7 wird auf die obigen Ausführungen zum Anspruch 1 verwiesen. Auch wenn Anspruch 1 ein Verfahren betrifft, ist der technische Gehalt der Merkmale beider Ansprüche identisch. 173

IV. 174

Angebot und Vertrieb der angegriffenen Smartphones und Tablets durch die Beklagten begründen eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG. Mit der Klage angegriffen sind alle Mobiltelefone und Tablets, die vom Profil HE AAC v2 des AAC-Standards Gebrauch machen. Dies hat die Klägerin unzweideutig in der Replik (dort Seite 39) 175

klargestellt. Dass der Klageantrag lediglich den Wortlaut der Klagepatentansprüche wiedergibt, ist unbeachtlich, da der Streitgegenstand durch die Klarstellung der Klägerin hinreichend bestimmt ist.

1.

Die angegriffene Ausführungsform ist objektiv geeignet, das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Klagepatents anzuwenden. Die Lehre des Klagepatentanspruchs 1 ist essentiell für den Standard, hier: das Parametric Stereo Tool, so dass eine standardkonforme Implementierung eines Dekodierers zwangsläufig die Eignung zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens nach sich zieht. Die angegriffene Ausführungsform entspricht aber den Anforderungen des Standards. Im Übrigen ergibt sich die Eignung zur Anwendung des Verfahrens nach dem Klagepatent auch aus den von der Klägerin durchgeführten Tests. 176

a)

Eine Implementierung des Parametric Stereo Tool des Standards in einem Dekodiergerät führt zwangsläufig dazu, dass der Dekodierer zur Anwendung des patentgeschützten Verfahrens geeignet ist, weil der Standard die Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 für die Durchführung der parametrischen Stereodekodierung voraussetzt. Dies ist zwischen den Parteien mit Ausnahme von Merkmal 1c auch unstreitig. 177

Merkmal 1c sieht den Erhalt eines Korrelationsparameters vor, der die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit der ausgegebenen Signale L und R vorgibt. Dies sieht auch der Standard mit dem sogenannten IIC-Parameter vor, der in Abschnitt 8.6.4.1 näher beschrieben wird: 178

8.6.4.1 Stereo parameters 179

Three different types of stereo parameters are used in representing the stereo image. For in total a maximum of 23 bands, one set of stereo parameters is available per band. […] 180

3) The inter-channel coherence ICC, defining the (dis)similarity of the left and right band-limited signal. 181

Der Parameter ICC gibt die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit des linken und rechten bandbegrenzten Signals an und entspricht damit dem Korrelationsparameter der erfindungsgemäßen Lehre. Das stellen auch die Beklagten im Grundsatz nicht in Abrede. Soweit sie aber der Auffassung sind, es sei erforderlich, dass im Standard darüber hinaus ein Konzept des „Maximalwerts der Kreuzkorrelation“ Anwendung finde, kann dem bei zutreffender Auslegung des Klagepatentanspruchs nicht gefolgt werden. 182

b)

Die angegriffene Ausführungsform unterstützt den Standard, hier das Parametric Stereo Tool des HE AAC v2-Profils des AAC Audiostandards. Denn die angegriffenen Geräte verwenden das mobile Betriebssystem Android, das – etwa in der Version 7.0, die auch in der angegriffenen Ausführungsform verwendet wird – die Unterstützung des HE AAC v2-Profils verlangt. Dies ergibt sich unter anderem aus den von dem Unternehmen Google aufgestellten 183

Kompatibilitätsvorgaben für das Betriebssystem Android in der Version 7.0, die als Anlage K 3h vorliegen. Ohne die Implementierung des Standards fehlt es an der erforderlichen Kompatibilität mit den Anforderungen an das Betriebssystem Android, so dass eine Zertifizierung durch Google nicht erfolgt. Dem sind die Beklagten nicht erheblich entgegengetreten. Auch wenn aus der Compatiblity Definition nicht zwingend folgt, dass Geräte mit dem Betriebssystem Android in jedem Fall tatsächlich das entsprechende Betriebssystem unterstützen, haben die Beklagten nicht in Abrede gestellt, dass die angegriffene Ausführungsform Standard-kompatibel ist.

Die Implementierung des Standards in der angegriffenen Ausführungsform hat die Klägerin zudem durch die von ihr durchgeführten Tests aufgezeigt, die sie als Anlage K 3i (Print) bzw. K 3j (digital) vorgelegt hat. Die dagegen vorgebrachten Einwendungen der Beklagten greifen nicht durch. Die von ihr aufgezählten methodischen Mängel, Unklarheiten und Widersprüche stellen die Testergebnisse letztlich nicht in Frage. 184

aa) 185

Der Einwand, die für die Tests vorgenommene Ende-zu-Ende-Messung sei ein methodisch fehlerhafter Ansatz, ist ohne Substanz, weil die Beklagten selbst nicht vortragen, welche konkreten Faktoren das Eingangssignal von der USB-Schnittstelle bis zum Dekodereingang beziehungsweise die Ausgangssignale vom Ausgang des Dekoders bis zur Audiobuchse der angegriffenen Ausführungsform in welcher Weise verändert haben sollen, so dass die Tests eine Aussage über das Dekodierverhalten und insbesondere die Implementierung des Standards nicht mehr zulassen. Im Übrigen belegen die Testergebnisse die Implementierung des Standards, so dass es der Beklagten oblegen hätte darzulegen, wie diese Ausgangssignale zustande kommen, wenn nicht durch Anwendung der Vorgaben des Standards. 186

bb) 187

Da der Referenzdecoder diesen Vorgaben entspricht und damit für die Durchführung des patentgemäßen Verfahrens geeignet ist, können sich die Beklagten auch nicht mit Erfolg auf den Einwand zurückziehen, die Klägerin habe die Kausalität des patentgeschützten Verfahrens für die in den Tests mit der angegriffenen Ausführungsform synthetisierten Daten nicht nachgewiesen. Gerade weil das Verhalten der angegriffenen Ausführungsform, insbesondere die synthetisierten Ausgangssignale, dem Verhalten des Referenzdecoders entspricht, kann auf die Anwendung des patentgemäßen Verfahrens geschlossen werden. Das gilt auch für die Leveldifferenz, die in den Tests der angegriffenen Ausführungsform vielleicht nicht den Werten des Standards, wohl aber den Referenzwerten entsprachen. Für ein erhebliches Bestreiten genügt es insoweit nicht, lediglich die Testergebnisse in Abrede zu stellen. 188

cc) 189

Was die Leveldifferenz angeht, hat die Klägerin erläutert, warum es in den Tests zu Abweichungen gegenüber den Werten im Standard gekommen ist. Die Abweichungen könnten sich daraus ergeben haben, dass die Rahmen des Signals, denen jeweils eine bestimmte Pegeldifferenz zugewiesen werde, nicht unabhängig voneinander vom Frequenzbereich in den Zeitbereich transformiert worden seien und diese Rahmen nicht genau den Signalabschnitten entsprächen, die zur Ermittlung der Pegeldifferenz zwischen den Ausgangskanälen im Zeitbereich ausgewertet würden. Dem sind die Beklagten nicht erheblich entgegengetreten. 190

dd) 191

Schließlich lassen die Tests an einem einzelnen Smartphone auch Rückschlüsse auf die angegriffenen Tablets zu. Denn die Tests stehen pars pro toto exemplarisch für die Funktionsweise aller von der angegriffenen Ausführungsform erfassten Geräte und damit auch für die angegriffenen Tablets. Dass diese eine technisch abweichende Funktionsweise hätten, behaupten auch die Beklagten nicht. 192

ee) 193

Im Ergebnis hat die Klägerin durch den Verweis auf den Standard, die „compatibility definition“ und die von ihr durchgeführten Tests über die bloße Behauptung der Merkmalsverwirklichung hinaus hinreichend zur Standardkompatibilität und zur Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur Durchführung des geschützten Verfahrens vorgetragen. Unter Berücksichtigung der wechselseitigen Darlegungslasten durften sich die Beklagten für ein erhebliches Bestreiten nicht darauf beschränken, den Vortrag der Klägerin lediglich in Abrede zu stellen oder mit Nichtwissen zu bestreiten, sondern hätten sich konkret zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform einlassen müssen. Daran fehlt es hier. 194

2.

Handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein Mittel, das für die Anwendung des patentgemäßen Verfahrens geeignet ist, bezieht es sich regelmäßig auch auf ein wesentliches Element der Erfindung. Das ist nämlich der Fall, wenn das Mittel geeignet ist, mit einem wesentlichen, nämlich im Patentanspruch genannten Erfindungselement funktional so zusammenzuwirken, dass es zu einer Verwirklichung des Erfindungsgedankens kommt (BGH GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 570 – extracoronales Geschiebe). Im Streitfall setzt die Anwendung des patentgeschützten Verfahrens notwendigerweise ein Mittel zur Anwendung des Verfahrens voraus, das somit den Erfindungsgedanken regelmäßig verwirklicht. 195

3.

Die Beklagten bieten die angegriffene Ausführungsform an und liefern sie, jedenfalls wirken sie an entsprechenden Lieferungshandlungen mit. 196

a)

Die Beklagten bieten die angegriffene Ausführungsform an im Sinne von § 10 Abs. 11 PatG. 197

Der Begriff „Anbieten“ deckt sich mit dem Begriff „Anbieten“ in § 9 S. 2 Nr. 1-3 PatG (OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 Rn 65; Benkard/Scharen, PatG 11. Aufl.: § 10 Rn 12). Ein Anbieten im Sinne von 9 S. 2 PatG umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert darauf gerichtet ist, das beworbene Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitzustellen (BGH, GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel; GRUR 1970, 358 - Heißläuferdetektor; OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 05732). Das Angebot muss deshalb keine gemäß § 145 BGB rechtswirksame Vertragsofferte 198

enthalten und setzt damit insbesondere nicht die Angabe von Preisen oder weiteren Einzelheiten voraus. Der Begriff des Anbietens umfasst vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das - wie beim Abschluss eines Kaufvertrages - die Benutzung dieses Gegenstands einschließt (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 259 (261) - Thermocycler). Es kommt auch nicht darauf an, ob der Anbietende mit seiner Offerte eigene Geschäftsabschlüsse forcieren will oder ob das Angebot einem Dritten zugutekommen soll, für dessen Produkt mit dem Angebot eine zu befriedigende Nachfrage geschaffen wird. In dem einen wie in dem anderen Fall ist die Rechtsposition des Schutzrechtsinhabers in gleichem Maße beeinträchtigt, weil eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegenständen geweckt wird, die das Ausschließlichkeitsrecht aus dem Patent schmälert. Insofern entspricht es der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass zur Gewährleistung eines wirksamen Patentschutzes nur von Belang ist, ob mit der fraglichen Handlung für einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand tatsächlich eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird. Wer das angebotene Erzeugnis später zur Verfügung stellt, hat keine Bedeutung. Bezweckt das Angebot den Geschäftsabschluss mit einem Dritten, so ist es deswegen unerheblich, ob der Anbietende von dem Dritten beauftragt oder bevollmächtigt ist (BGH, GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel).

Es ist zu Recht unstreitig, dass die Beklagte zu 2) in ihrem Internetauftritt die angegriffene Ausführungsform anbietet. Unerheblich ist, dass aus der Produktabbildung nicht unmittelbar die patentverletzenden Eigenschaften erkennbar sind. 199

Aber auch die Beklagte zu 1) bietet die angegriffene Ausführungsform in diesem Sinne an, indem sie Smartphones und Tablets der Marke XXX in ihrem Facebook-Auftritt präsentiert. Da für ein Anbieten auch die Förderung des Vertriebs durch Dritte genügt, kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte zu 1) selbst Vertriebsabsichten hat und die angegriffene Ausführungsform über die Beklagte zu 1) bezogen werden kann. Schon die Konzernverbundenheit der beiden Beklagten sowie die Funktion der Beklagten zu 1), lokale Marketingunterstützungsmaßnahmen für die Marken des XXX Konzerns zu ergreifen, lassen überhaupt keinen anderen Schluss zu, als dass die Beklagte zu 1) mit der Präsentation von Modellen der angegriffenen Ausführungsform in ihrem Facebook-Auftritt Nachfrage nach der angegriffene Ausführungsform weckt, die durch die Beklagte zu 2) bzw. deren Vertriebspartner befriedigt werden kann. Es handelt sich um Werbemaßnahmen, die uneingeschränkt dem Begriff „Anbieten“ im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1-3 PatG unterfallen (Schulte/Rinken, PatG 10. Aufl.: § 9 Rn 62). 200

b)

Die Beklagten verwirklichen den Tatbestand von § 10 Abs. 1 PatG auch in der Variante „Liefern“ des Mittels. 201

aa) 202

Die Beklagte zu 2) liefert die angegriffene Ausführungsform in die Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung im Inland. 203

Der Begriff „Liefern“ im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG setzt die Übergabe des Mittels an einen anderen voraus (Benkard/Scharen, PatG 11. Aufl.: § 10 Rn 13) und entspricht damit dem 204

Begriff „Inverkehrbringen“ im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 und 3 PatG. Ein Inverkehrbringen ist jedwede Tätigkeit, durch die der Eintritt des patentierten Erzeugnisses in den Handelsverkehr, der Umsatz- und Veräußerungsgeschäfte zum Gegenstand hat, tatsächlich bewirkt wird, indem das patentierte Erzeugnis unter Begebung der eigenen Verfügungsgewalt tatsächlich in die Verfügungsgewalt einer anderen Person übergeht (Benkard/Scharen, PatG 11. Aufl.: § 9 Rn 44).

Es ist unstreitig, dass die Beklagte zu 2) in diesem Sinne die angegriffene Ausführungsform in die Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung der Erfindung liefert. 205

bb) 206

Auch wenn die Beklagte zu 1) eigenhändig keine Lieferhandlungen vornimmt, wirkt sie gleichwohl an den Lieferhandlungen der Beklagten zu 2) mit und haftet für diese. 207

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes setzt die Verantwortlichkeit für eine Patentverletzung nicht voraus, dass der in Anspruch genommene in seiner Person eine der in § 9 S. 2 PatG bezeichneten Handlungen vornimmt. Schuldner der Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung der verletzenden Gegenstände kann vielmehr auch sein, wer lediglich eine weitere Ursache für die Rechtsverletzung setzt, indem er eine von ihm ermöglichte Rechtsverletzung durch einen Dritten nicht unterbindet, obwohl dies von ihm zu erwarten wäre (BGH, GRUR 2009, 1142, 1145 – MP3-Player-Import). Die Rechtfertigung für die Zurechnung der fremden Schutzrechtsverletzung besteht in der Regel in der Verletzung einer Rechtspflicht, die jedenfalls auch dem Schutz des verletzten absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder jedenfalls als verbotener und daher zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre (BGH, GRUR 2009, 1142, 1145 – MP3-Player-Import). Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist daher nicht nur, wer in eigener Person einen der Benutzungstatbestände des § 9 PatG verwirklicht oder vorsätzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht oder fördert. Verletzer und damit Schuldner ist vielmehr auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch den Dritten ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import). 208

Nach diesen Grundsätzen, die auf das Liefern im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG ohne Einschränkung übertragbar sind, sind der Beklagten zu 1) die Lieferhandlungen der Beklagten zu 2) zuzurechnen. Die Beklagte zu 1) fördert nicht nur mit Werbemaßnahmen in ihrem Facebook-Auftritt den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagte zu 2), sondern führt mit einem Link in diesem Facebook-Auftritt auch zur Website der Beklagten zu 2), von wo aus die angegriffene Ausführungsform – jedenfalls über dort angegebene Händler – erworben werden kann. Der Beklagten zu 1) oblag es auch, Maßnahmen zu ergreifen, die eine Verletzung des Klagepatents ausschließen. Dies war ihr durchaus möglich, auch wenn sie selbst keine technische Expertise hat, sondern nur Marketingunterstützung leistet. Die Beklagte zu 1) tritt als Gesellschaft des XXX Konzerns im Geschäftsverkehr auf. Durch ihre Spezialisierung auf das Marketing für Produkte des Konzerns ist sie kein unbeteiligter Dritter wie der Spediteur oder Frachtführer in der zitierten Entscheidung „MP3-Player-Import“, deren Dienstleistungen im Allgemeinen in keinem spezifischen Zusammenhang mit den patentverletzenden Eigenschaften des Produkts stehen. Vielmehr kann von der Beklagten zu 1), weil ihre Geschäftstätigkeit auf die Förderung 209

des Vertriebs technischer Produkte gerichtet ist, für die bekanntermaßen eine Vielzahl von Schutzrechten in Kraft ist, erwartet werden, dass sie sich jedenfalls bei der von ihr unterstützen Beklagten zu 2) zuvor über die Möglichkeit einer Patentverletzung informiert, zumal davon ausgegangen werden kann, dass dies aufgrund der gemeinsamen Konzernzugehörigkeit beider Beklagten unschwer möglich gewesen wäre.

4.

Bei den Angebotsempfängern und den (End-)Abnehmern der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um Personen, die zur Benutzung der Erfindung nicht berechtigt sind. Das ist gemäß § 10 Abs. 3 PatG auch dann der Fall, wenn es sich dabei um Verbraucher handelt, die die angegriffene Ausführungsform gemäß § 11 Nr. 1 PatG lediglich im privaten Bereich zu nicht-gewerblichen Zwecken verwenden. 210

5.

Für die Beklagten ist es jedenfalls offensichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform dazu geeignet und seitens der Abnehmer dazu bestimmt ist, für die Durchführung des patentgemäßen Verfahrens verwendet zu werden. 211

Für die Offensichtlichkeit ist maßgeblich, ob im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung nach den gesamten Umständen des Falls die drohende Patentverletzung aus der Sicht des Anbieters oder Lieferanten so deutlich erkennbar war, dass ein Angebot oder eine Lieferung der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist (BGH GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). Es genügt, wenn aus der Sicht des Dritten mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgemäßer Weise verwenden wird (BGH GRUR 2006, 839 – Deckenheizung). Abgesehen von den Fällen ausschließlich patentgemäß verwendbarer Mittel ist dies regelmäßig insbesondere dann der Fall, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit patentgemäßer Verwendung hinweist oder diese gar empfiehlt (BGH GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). 212

Im Streitfall ergibt sich die Anwendung des patentgemäßen Verfahrens zwangsläufig dann, wenn der Nutzer der angegriffene Ausführungsform Audiodateien abspielt, die nach dem AAC-Standard gemäß dem Profil HE AAC v2 codiert sind. Da die angegriffene Ausführungsform – sei es in der Form des Smartphones oder des Tablets – bekanntermaßen regelmäßig auch dem Abspielen von Audiodaten dient, ist die Anwendung des patentgemäßen Verfahrens sicher zu erwarten. Der Nutzer hat in der Regel kein Interesse daran, mit welchem Dateiformat Audiodaten auf die angegriffene Ausführungsform heruntergeladen oder gestreamt werden. Ihm geht es darum, dass die Datei korrekt wiedergegeben wird. Häufig besteht auch gar keine Auswahlmöglichkeit zwischen den Dateiformaten. Da nach dem AAC-Standard codierte Audiodaten auch keine Seltenheit sind, ist eine patentgemäße Verwendung der angegriffenen Ausführungsform sicher zu erwarten. 213

V. 214

215

Die Beklagten benutzen die Lehre des Klagepatentanspruchs 7 auch im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.

1.

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 7. Zur Begründung kann ohne Einschränkung auf die vorangehenden Ausführungen zur objektiven Eignung zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Klagepatents verwiesen werden. Denn aus der objektiven Eignung folgt aufgrund der technischen Übereinstimmung der Merkmale beider Ansprüche zwangsläufig, dass die angegriffene Ausführungsform auch die Mittel zur Anwendung dieses Verfahrens umfasst und somit Mittel im Sinne der Merkmale 7b bis 7e umfasst. 216

2.

Die Beklagten bieten die angegriffene Ausführungsform an im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Weiterhin bringt die Beklagte zu 2) mit Unterstützung der Beklagten zu 1) die angegriffene Ausführungsform gemäß § 9 S. 2 Nr. 1 PatG in den Verkehr. Zur Begründung kann ohne Einschränkung auf die Ausführungen zum Anbieten und Liefern der angegriffenen Ausführungsform im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG verwiesen werden. 217

VI. 218

Das Klagepatent entfaltet Wirkung auch im Hinblick darauf, dass das Unternehmen XXX Lizenznehmer des XXX Pools ist und das Betriebssystem Android, das die Kompatibilität der angegriffenen Ausführungsform mit dem AAC-Standard verlangt, von Google stammt. Eine Erschöpfung des Patentrechts ist dadurch nicht eingetreten. 219

Erschöpfung meint Verbrauch des Patentrechts hinsichtlich eines bestimmten (einzelnen) patentgemäßen Erzeugnisses (BGH GRUR 1997, 116 – Prospekthalter). Wurde eine Sache, die die technische Lehre eines für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten Vorrichtungspatents verwirklicht, vom Patentinhaber oder von einem von diesem ermächtigten Dritten in Deutschland, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU) oder einem dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehörigen Staat in den Verkehr gebracht, unterliegen das weitere Inverkehrbringen, Anbieten und Gebrauchen dieser Sache nicht mehr dem Verbietungsrecht aus dem Patent (BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren; GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter; GRUR 2001, 223, 224 – Bodenwaschanlage). Gleiches gilt bei einem Verfahrenspatent für die nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG geschützten unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, soweit diese vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden (BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren; GRUR 2001, 223, 224 – Bodenwaschanlage). 220

Nach diesen Grundsätzen ist Erschöpfung nicht eingetreten. Nach dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin ist XXX zwar Lizenznehmerin des XXX Pools, ist aber nur berechtigt, bestimmte eigene Produkte wie Mobiltelefone, Streaming-Geräte oder Smart Speaker anzubieten und in den Verkehr zu bringen. Das Betriebssystem Android oder Teile davon sind nicht Teil des Lizenzvertrages und XXX zahlt dafür auch keine Lizenzgebühren. Etwas anderes behaupten auch die Beklagten nicht. 221

VII. 222

Aus der Benutzung der Erfindung gemäß §§ 9, 10 PatG durch die Beklagten ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen. 223

1.

Die Beklagten sind der Klägerin gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, da die Benutzung der Erfindung ohne Berechtigung erfolgt. 224

Die Verhängung eines Schlechthinverbots ist dabei auch gerechtfertigt, soweit der Unterlassungsanspruch auf Benutzungshandlungen im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG gestützt ist. Zwar kommt ein Schlechthinverbot im Rahmen einer nur mittelbaren Patentverletzung regelmäßig dann nicht in Betracht, wenn die angegriffene Ausführungsform auch patentfrei benutzt werden kann (vgl. Schulte/Rinken, PatG 10. Aufl.: § 10 Rn 34 ff). Dabei müssen die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden. 225

Im Streitfall kann die angegriffene Ausführungsform zwar auch patentfrei genutzt werden, indem keine Audiodateien abgespielt werden oder nur solche Audiodaten, die nicht gemäß dem AAC-Standard codiert sind. Wird aber eine Audiodatei abgespielt, hängt es weder vom Willen der Beklagten, noch von dem der Nutzer der angegriffenen Ausführungsform ab, ob von der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 Gebrauch gemacht wird, sondern allein vom verfügbaren Dateiformat. Handelt es sich um eine Audiodatei gemäß dem AAC-Standard, kommt es zwangsläufig und ohne weiteres Zutun des Nutzers zur Patentverletzung. Wird weiterhin berücksichtigt, dass Nutzer die angegriffene Ausführungsform bekanntermaßen durchweg auch zum Abspielen von Audiodateien verwenden, ist mit einer Verletzung des Klagepatents durch jede angegriffene Ausführungsform aufgrund der Verbreitung des AAC-Formats fast zwangsläufig zu rechnen. Da sowohl ein Warnhinweis als auch eine Vertragsstrafenvereinbarung zur Verhinderung einer Patentverletzung ins Leere laufen und im Fall der Vertragsstrafenvereinbarung bei privaten Endabnehmern ohnehin nicht in Frage kommen, ist im Streitfall ein Schlechthinverbot gerechtfertigt. 226

2.

Die Klägerin hat gegen die Beklagten dem Grunde nach Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 und 2 PatG. 227

a)

Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht. 228

b)

Zudem sind die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs aus § 139 Abs. 2 PatG erfüllt. Die Beklagten begingen die Patentverletzung rechtswidrig und schuldhaft. Als Fachunternehmen hätten sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. 229

c)

Die Beklagten sind auch nicht berechtigt, die Zahlung von Schadensersatz gemäß § 214 Abs. 1 PatG zu verweigern. Denn die Verjährung des Anspruchs ist bislang nicht eingetreten. 230

aa) 231

Die regelmäßige Verjährung ist bislang nicht eingetreten. 232

Gemäß § 141 S. 1 PatG finden auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Patentrechts die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechende Anwendung. Demnach beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, § 199 Abs. 1 BGB. 233

Im Streitfall lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerin bereits im Jahr 2015 oder früher Kenntnis von allen anspruchsbegründenden Tatsachen einschließlich von den Beklagten als Schuldner des Anspruchs hatte. Dass die Klägerin positive Kenntnis hatte, ist seitens der Beklagten nicht vorgetragen. Eine solche Kenntnis ergibt sich auch nicht daraus, dass die Klägerin gegebenenfalls frühzeitig darüber informiert war, dass die Muttergesellschaft im Jahre 2005 eine Pool-Lizenz genommen hatte, die alsbald wieder beendet wurde. Für eine Kenntnis von der Beteiligung der Beklagten an patentverletzenden Handlungen ergibt sich daraus nichts. 234

Es lässt sich aber auch nicht feststellen, dass die Klägerin ohne grobe Fahrlässigkeit bereits im Jahr 2015 oder früher Kenntnis von den Beklagten hätte erlangen müssen. Es kann in Fällen wie dem vorliegenden nicht erwartet werden, dass ein Unternehmen wie die Klägerin, das ebenso wie XXX nicht in der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist, in allen Jurisdiktionen die Verjährungsfristen im Blick hat, um etwaige Ansprüche noch vor der Verjährung gerichtlich geltend machen zu können. Denn die Klägerin beziehungsweise XXX war bemüht, mit dem XXX Konzern eine weltweite Lizenz abzuschließen. Für den Fall des Scheiterns der Vertragsverhandlungen in allen Ländern, in denen standardessentielle Patente in Kraft sind, bereits die Verjährungsfristen im Blick zu haben, erscheint nicht nur aufgrund des damit verbundenen personellen und finanziellen Aufwands, der im Fall des Vertragsschlusses zudem vergeblich ist, als unangemessen, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass im Falle einer kurzen Verjährungsfrist die Klägerin gehalten wäre, Klage zu erheben und damit etwaige Vertragsverhandlungen zu belasten und einen Lizenzvertragsschluss zu gefährden. 235

Ungeachtet dessen lässt sich aber auch nicht feststellen, dass die Klägerin tatsächlich früher hätte Kenntnis von den Beklagten haben können als den Unternehmen, die in der Bundesrepublik Deutschland Patentverletzungen begehen. Den Vortrag der Beklagten, es sei ohne weiteres möglich gewesen, über Internetrecherche oder durch Blick auf die 236

Produktverpackung festzustellen, dass die Beklagten zu 1) und 2) auch schon im Jahr 2015 in der Bundesrepublik Deutschland Vertriebs- oder Marketingtätigkeiten entwickelten, hat die Klägerin ebenso wie die Behauptung, die Beklagten, jedenfalls aber die Beklagte zu 2), seien auf der IFA tätig gewesen, mit Nichtwissen bestritten. Beweis haben die Beklagten für ihre Behauptungen nicht angetreten.

bb) 237

Nachdem die Klägerin den Schadensersatzanspruch auf seit dem 30. Oktober 2009 begangene Handlungen beschränkt hat, ist auch die absolute Verjährung nicht eingetreten. 238

Gemäß § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB verjähren Schadensersatzansprüche ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. 239

Für am 30. Oktober 2009 (und später) begangene Handlungen ist das Ende dieser zehnjährigen Frist, die mit Ablauf des 30. Oktober 2019 (und entsprechend später) geendet hätte, jedoch noch nicht eingetreten, weil die Zeit ab Einreichung der Klage am 30. Oktober 2019 gemäß § 209 BGB nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet wird. Denn an diesem Tag ist die Hemmung der Verjährung eingetreten. Grundsätzlich tritt die Hemmung mit der Erhebung der Klage gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB ein. Im Streitfall ist jedoch gemäß § 167 ZPO auf den Eingang der Klage bei Gericht am 30. Oktober 2019 abzustellen, weil mit der Zustellung der Klage die Verjährung gehemmt werden soll. 240

3.

Der Klägerin steht gegen die Beklagten auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. 241

Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. 242

Die auch gegen diesen Anspruch erhobene Einrede der Verjährung greift nicht durch. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zur Verjährung des Schadensersatzanspruchs verwiesen. 243

4.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 2) einen Anspruch auf Rückruf und Entfernung der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG, soweit diese Erzeugnisse nach dem 9. April 2017 in den Verkehr gebracht wurden. Gegen die Beklagte zu 1) besteht ein solcher Anspruch nicht. 244

a)

Die Beklagte zu 2) ist zum Rückruf und zur Entfernung der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen verpflichtet, soweit die Erzeugnisse in den letzten vier Jahren vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung am 9. April 2017 in den Verkehr gelangten. 245

Der Rückruf von zeitlich vor dem 9. April 2017 in den Verkehr gebrachten Erzeugnissen ist ausgeschlossen, da er unverhältnismäßig ist im Sinne von § 140a Abs. 4 PatG. 246

Ob der Rückruf und die Entfernung aus den Vertriebswegen unverhältnismäßig ist, erfordert eine Abwägung der maßgeblichen Umstände des Einzelfalls (Benkard/Grabinski/Zülch, PatG 11. Aufl.: § 140a Rn 8a). Dazu gehören neben der Schwere des Schutzrechtseingriffs und dem Grad des Täterverschuldens auch das Rückruf-/Entfernungsinteresse des Verletzten, das entgegengesetzte Verhaltensinteresse des Verletzers sowie die Gesichtspunkt der Generalprävention und der Sanktionierung für ein rechtsverletzendes Tun (BGH GRUR 2019, 518 – Curapor). 247

Vor diesem Hintergrund ist der Rückruf- und Entfernungsanspruch gegen die Beklagte zu 2) grundsätzlich verhältnismäßig. Es handelt sich um den typischen Fall einer Patentverletzung, der einen Rückruf und die Entfernung der patentverletzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen nach sich zieht. Die Kammer vermag insofern auch nicht die Auffassung zu teilen, dass die Lehre des Klagepatents lediglich einen geringen Anteil am Funktionsumfang der angegriffenen Ausführungsform habe und daher eine vollständige Beseitigung aus den Vertriebswegen ausscheiden müsse. Zwar handelt es sich bei den angegriffenen Erzeugnissen um komplexe Geräte mit einer Vielzahl technischer Funktionen. Aber gerade weil mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets bekanntermaßen nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zum Abspielen von Audio- und Videodateien verwendet werden, ist der Anteil der Lehre des Klagepatents am Funktionsumfang der angegriffenen Ausführungsform nicht zu vernachlässigen und rechtfertigt den Rückruf und die Entfernung aus den Vertriebswegen. 248

Ebenso wenig kann die Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs damit begründet werden, dass die Eignung zur Patentverletzung durch ein Softwareupdate beseitigt werden könne. Es ist nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich, wie ein solches Softwareupdate bewerkstelligt werden soll, das jegliche Patentverletzung ausschließt, ohne dass es von den Abnehmern unproblematisch beseitigt werden kann. 249

Der Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen erweist sich jedoch als unverhältnismäßig, soweit Erzeugnisse zurückgerufen werden sollen, die vor dem 9. April 2017 in den Verkehr gebracht wurden. Bei weit zurückliegenden Zeiträumen kann die Situation entstehen, dass keine realistische Aussicht mehr besteht, dass sich der verletzende Gegenstand noch beim Abnehmer, von dem zurückgerufen wird, befindet. Hier kommt ein (zweckloser) Rückruf regelmäßig nicht in Betracht, da er keine weiteren Vertriebswege mehr freimachen und keine Nachfrage zugunsten des Patentinhabers generieren kann (vgl. Kühnen, Hb. der Patentverletzung, 13. Aufl.: Kap. D Rn 896). 250

So liegt der Fall hier. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich in den Vertriebswegen noch eine nennenswerte Anzahl von Smartphones oder Tablets befindet, die vor fünf, sieben oder zehn Jahren von der Beklagten zu 2) ausgeliefert wurden. Die Beklagten haben vorgetragen, dass die Verkaufsdauer aktueller Modelle durchschnittlich zwei bis vier Jahre betrage. Es erscheint daher angemessen, den Rückrufanspruch auf die letzten 251

vier Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung zu beschränken. Denn der Zeitraum von vier Jahren schließt weder aus, dass zu Beginn dieses Zeitraums auch noch Vorgängermodelle veräußert wurden, noch ist ausgehend von einer Verkaufsdauer von vier Jahren anzunehmen, dass gewerbliche Abnehmer im nennenswerten Umfang noch Smartphones oder Tablets vorrätig haben, die vor über vier Jahren geliefert wurden. Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung die durchschnittliche Verkaufsdauer mit Nichtwissen bestritten und die Auffassung vertreten hat, der Rückruf gehe für weiter zurückliegende Zeiträume dann gegebenenfalls ins Leere, ist dies unerheblich. Die Unverhältnismäßigkeit ist vielmehr gerade dann begründet, wenn von dem Verletzer ein Verhalten gefordert wird, dass sich von vornherein als (nahezu) aussichtslos erweist. Das ist bei Lieferungen, die über vier Jahre zurückliegen, anzunehmen. Auch wenn die Klägerin selbst keine Smartphones und Tablets anbietet oder vertreibt, kann sie sich als ein in der Lizenzvergabe tätiges Unternehmen nicht auf die Unkenntnis der durchschnittlichen Verkaufsdauer von Mobilfunkgeräten zurückziehen, zumal entsprechende Zahlen am Markt erhältlich sein dürften.

b)

Ein Anspruch auf Rückruf und Entfernung der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen besteht gegen die Beklagte zu 1) nicht. Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um ein reines Marketingunternehmen, das in den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland nicht involviert ist. Hat die Beklagte zu 1) aber selbst keine Vertriebshandlungen vorgenommen und stellt sich damit nicht als Vertragspartner eines patentverletzenden Veräußerungsgeschäfts dar, ist es ihr auch nicht möglich, sie als Berechtigte zur Rückabwicklung eines Liefergeschäfts auszuweisen (vgl. Kühnen, Hb. der Patentverletzung, 13. Aufl.: Kap. D Rn 888 zum Geschäftsführer). 252

5.

Ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) aus § 140a Abs. 1 PatG auf Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform besteht ebenfalls nicht. 253

Der Anspruch setzt voraus, dass der Schuldner im Schluss der mündlichen Verhandlung Eigentum oder Besitz an den patentverletzenden Erzeugnissen hat. Daran fehlt es hier. 254

Im Allgemeinen genügt die Behauptung, dass der Verletzer zu irgendeinem Zeitpunkt nach Erteilung des Patents im Besitz oder Eigentum schutzrechtsverletzender Gegenstände war. Es ist sodann Sache des Verletzers, in erheblicher Art und Weise darzutun und gegebenenfalls zu beweisen, dass trotz des vorher bestehenden Besitzes und/oder Eigentums nunmehr weder Besitz noch Eigentum bei ihm vorhanden sind. Ein pauschales Bestreiten des Besitzes und/oder Eigentums oder das schlichte Behaupten, jetzt keinen Besitz und/oder Eigentum mehr zu haben, reicht in diesem Zusammenhang nicht. Vielmehr obliegt es dem Verletzer, substantiiert konkrete Tatsachen vorzutragen, aus denen sich ergibt, dass und durch welches Geschehen der Besitz und/oder das Eigentum vollständig aufgegeben wurde (LG Düsseldorf, InstGE 13, 1 – Escitalopram-Besitz). 255

Im Streitfall fehlt es bereits an Vortrag dazu, dass die Beklagte zu 1) überhaupt einmal Eigentum oder Besitz an der angegriffenen Ausführungsform hatte. Nach dem unbestrittenen 256

Vortrag der Beklagten zu 1), zuletzt wiederholt in der mündlichen Verhandlung, hat sie weder Besitz noch Eigentum an der angegriffenen Ausführungsform. Es handelt sich bei ihr unstreitig um ein reines Marketingunternehmen, das in den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland nicht involviert ist.

VIII. 257

Die Durchsetzung der auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichteten Ansprüche ist durch den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nicht gehindert. 258

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung (dazu unter Ziff. 1) gemessen an Art. 102 AEUV missbraucht (dazu insgesamt unter Ziff. 2). 259

1.

Das Klagepatent vermittelt der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung auf den hier relevanten Märkten für „Smartphones“ bzw. für „Tablets“. 260

a)

„Marktbeherrschung“ meint in dem streitgegenständlichen Kontext die wirtschaftliche Macht, die es einem Unternehmen erlaubt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem (zeitlich, räumlich und sachlich relevanten) Markt zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, Abnehmern und den Verbrauchern gegenüber in nennenswertem Umfang unabhängig zu verhalten (EuGH Slg. 78, 207 Rn. 65 f. – United Brands; EuGH Slg. 79, 461 Rn. 38 f. – Hoffmann-La Roche; BGH, GRUR 2020, 961, Rn. 55 – FRAND-Einwand). Bei der Marktbeherrschung handelt sich um einen objektiven Begriff, der auf eine tatsächliche wirtschaftliche Lage verweist (EuGH, GRUR 2015, 764, Rn. 45 – Huawei Technologies / ZTE; OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 126 – Mobiles Kommunikationssystem). Sie muss mindestens auf einem wesentlichen Teil des Binnenmarktes bestehen. 261

Die notwendige exakte Abgrenzung des Marktes in sachlicher und räumlicher Hinsicht erfolgt mittels des sog. Bedarfsmarktkonzepts (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 127). Es sind diejenigen Wettbewerbskräfte zu eruieren, denen die betreffenden Unternehmen unterliegen (a.a.O.). Ferner werden diejenigen Unternehmen bestimmt, welche tatsächlich in der Lage sind, dem Verhalten der beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen und einen Entzug von Wettbewerbsdruck verhindern. Es ist zu klären, welche Produkte bzw. Dienstleistungen aus der Sicht der Nachfrager funktionell gegeneinander austauschbar sind. Demselben sachlichen Markt wird zugeordnet, was aufgrund der jeweiligen Eigenschaften, Preise und Verwendungszwecke aus Sicht der Nachfrager nicht durch andere Produkte bzw. Dienstleistungen substituierbar ist. Zu berücksichtigen ist dabei ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren (bspw. Marktanteil, Unternehmensstruktur, Wettbewerbssituation, Verhalten auf dem Markt; grds. jedoch nicht der Preis) (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt – wie jeder Mitgliedstaat – zugleich einen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes dar (BGH, ebd., Rn. 64). 262

Im Zusammenhang mit den hier geltend gemachten Verbietungsrechten aus einem Patent ist die geschilderte Abgrenzung in Bezug auf den Lizenzvergabemarkt vorzunehmen (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 128; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Auflage, 2021, Kap. E., Rn. 263

230): Anbieter ist der Patentinhaber, dem allein eine Lizenzvergabe an dem jeweiligen Patent möglich ist; Nachfrager ist der an der patentgeschützten Technik interessierte Anwender (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, a.a.O.). Auf diesem Lizenzvergabemarkt bedarf es einer beherrschende Stellung des Patentinhabers (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 231). Mit der bloßen Inhaberschaft von Patenten alleine ist noch keine marktbeherrschende Stellung verbunden (BGH, NJW-RR 2005, 269 (271) – Standard-Spundfass), und zwar auch dann nicht, wenn es sich um ein standardessentielles Patent (im Folgenden auch: SEP) handelt (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 129). Erhält der Patentinhaber allerdings aufgrund hinzutretender Umstände die Möglichkeit, mittels seiner Monopolstellung wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten Markt zu verhindern, so vermittelt ihm diese Wettbewerbsposition auf dem Markt für erfindungsgemäße Produkte eine marktbeherrschende Stellung auf dem vorgelagerten Lizenzvergabemarkt (EuGH, GRUR Int 1995, 490 – Magill TVG Guide; EuGH, WuW 2013, 427 – Astra Zeneca; BGH, NJW-RR 2010, 392 ff. – Reisestellenkarte; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 231). Ein solcher nachgeordneter Produktmarkt besteht für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen. Die Annahme eines in diesem Sinne eigenständigen Lizenzmarktes setzt voraus, dass es sich um ein standardessentielles Patent handelt, also die Benutzung der patentgeschützten Lehre für die Umsetzung eines (von einer Standardisierungsorganisation normierten oder auf dem Markt durchgesetzten) Standards unerlässlich ist, so dass es in der Regel technisch nicht möglich ist, diese zu umgehen, ohne für den Produktmarkt wichtige Funktionen einzubüßen (BGH, ebd., Rn. 58). Die dem Patent und dem Standard entsprechende technische Lehre darf auch nicht durch eine andere technische Gestaltung des Produkts substituierbar sein (a.a.O.).

Der Beklagte trägt für die Marktbeherrschung nach den allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 130; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 238). Er ist insoweit gehalten, ganz konkrete Tatsachen vorzutragen, die eine gerichtliche Überprüfung, ob eine beherrschende Stellung auf dem räumlich und sachlich relevanten Markt gegeben ist oder nicht, erlauben (Kühnen, a.a.O.). Für das Bestreiten des Patentinhabers gilt im Anschluss dasselbe Maß an Substantiierung (Kühnen, a.a.O.). 264

b)

Orientiert an vorstehenden Grundsätzen vermittelt das Klagepatent der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung auf den hier relevanten Produktmärkten für „Smartphones“ bzw. für „Tablets“. 265

Bei dem Klagepatent handelt es sich um ein für die Umsetzung des AAC-Standards wesentliches Patent (dazu unter Ziff. IV., 1.). 266

Trotz technischer Alternativen kann auch ein wettbewerbsfähiges Produkt ohne den streitgegenständlichen Standard nicht angeboten werden. 267

Dabei bedarf es im Ergebnis keiner Entscheidung über den Streit der Parteien, ob das Angebot eines wettbewerbsfähigen Produkts deshalb nicht möglich ist, weil führende Anbieter von Multimedia- und Streamingdiensten diesen vorgeben. Ohne den streitgegenständlichen Standard kann ein marktgängiges Produkt auf dem Smartphone- bzw. Tabletmarkt jedenfalls deshalb nicht bereitgestellt werden, weil dieser die Kompatibilität mit aus Sicht des Endabnehmers bedeutsamen Anwendungen im Zusammenhang mit dem Android-Betriebssystem gewährleistet (dazu unter lit. aa) und lit. cc)). Denn die Implementierung des AAC-Standards wird durch Google als Betreiber des marktführenden „Android“- 268

Betriebssystems vorgegeben, ohne dass ein alternatives Betriebssystem zur Verfügung stünde bzw. entwickelt werden könnte (dazu unter lit. bb) und lit. cc)).

aa) 269

Erfüllen die Hersteller der Smartphones die Kompatibilitätsanforderung nicht, steht dies einer „GMS“-Zertifizierung entgegen, die wiederum Voraussetzung dafür ist, dass bestimmte Google-Anwendungen (z. B. Google Play App Store, YouTube, Google Maps sowie die Google-Suche) genutzt werden können . 270

Die Beklagten machen geltend, dass – was die Kammer als potenzieller Endabnehmerkreis selbst beurteilen kann (vgl. zu diesem Maßstab allg. OLG Düsseldorf, GRUR 2017,1219, Rn. 130 – Mobiles Kommunikationssystem) – die Erwartungshaltung der Nutzer dahingehe, mit einem Betriebssystem auch alle für dieses bekannte Applikationen Nutzen zu können. Dies stützt der von den Beklagten vorgelegten Fachartikel „X ohne Google: 7 von 10 verzichten auf das neue Flaggschiff“ (Anlage B18), ausweislich dessen von den rund 1000 befragten Nutzern (Stand: 03. April 2020) 70 % angaben, dass sie von einem Kauf des neuen X-Smartphones („P40 Pro“) Abstand nehmen würden, wenn darauf Google- (Google Play Store, Google Maps, YouTube) nicht installiert seien. 271

Soweit die Klägerin bezugnehmend auf diesen Artikel den Rückschluss zieht, dass noch 30% der Befragten eine Kaufentscheidung auch ohne Google-Apps treffen würden, vermag die Kammer diesen Schluss auf Grundlage des hier in Rede stehenden Dokuments nicht zu ziehen. Der Einwand der Klägerin geht dahin, dass der Markt, der derzeit zu nahezu 100 % von dem Android-Betriebssystem einerseits (Marktanteil von ca. 74,6 %) und dem iOS-Betriebssystem andererseits (Markanteil von ca. 24,8%) abgedeckt wird, von einem alternativen Betriebssystem durchdrungen werden könnte. Dies ist indes aus den unter lit. (bb) ausgeführten Gründen nicht zu erwarten. 272

Auch soweit die Klägerin darauf verweist, dass auch in dem „Android-Ökosystem“ andere App-Stores nutzbar sind („Amazon Underground“, „Gretja“, „SlideME“ oder „Yandex Store“), ist gerade nicht ersichtlich, dass diese die Erwartungshaltung des Endabnehmers gleichermaßen befriedigen. Die Klägerin trägt zwar vor, dass der Google Play Store für Android-Tablets eine geringere Bedeutung habe, dass diese geringere Bedeutung der Annahme einer marktbeherrschenden Stellung entgegensteht ist indes nicht zu erkennen. Es verbleibt dabei, dass ohne die „GMS“-Zertifizierung auch andere - vom Endabnehmer als wesentlich erachteten – Google-Anwendungen nicht nutzbar sind. 273

bb) 274

Der Hersteller von Smartphones kann nicht darauf verwiesen werden, seinerseits ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln bzw. auf ein anderes Betriebssystem als das „Android-System“ auszuweichen – unstreitig sind alternative Systeme anderer Hersteller wie Nokia OS (Nokia), Windows Phone/ Mobile (Microsoft) und Blackberry OS (Blackberry) sowie Open Source Betriebssysteme verfügbar. 275

Das „Android-Betriebssystem“ ist auf dem Smartphone-Markt neben dem „iOS“-System, an dem Nutzungsrechte nicht erworben werden können, vorherrschend. Diese machen gemeinsam einen Marktanteil von nahezu 100% aus. Mit anderen existierenden Betriebssystemen kann demgegenüber allenfalls ein Nischenmarkt erschlossen werden. Insoweit ist der Vortrag der Beklagten, dem die Klägerin nichts Substantielles entgegengebracht hat, von Bedeutung, dass ein Großteil der Applikationen für 276

Mobilfunkgeräte allein auf die markbeherrschenden Betriebssysteme „Android“ und „iOS“ abgestimmt werde.

Aus den dargelegten Gründen ist den Beklagten schließlich auch nicht zumutbar, ein alternatives Betriebssystem zu schaffen, um so die Vorgabe zur Implementierung des streitgegenständlichen Standards, die sich bei Verwendung des Android-Betriebssystems ergibt, zu umgehen. 277

cc) 278

Soweit die Beklagten keine gesonderten Ausführungen zur beherrschenden Stellung der Klägerin auf dem „Tablet-PC-Markt“ machen, sondern auf die Übertragbarkeit ihrer Ausführungen zum Markt für „Smartphones“ verweisen, hat die Klägerin nichts vorgebracht, was dem entgegensteht. 279

2.

Ein Missbrauch der nach Maßgabe der Ausführungen unter Ziffer 1 bestehenden marktbeherrschenden Stellung kann nicht festgestellt werden. 280

Während der Klägerin nach der hier anwendbaren EuGH-Rechtsprechung (dazu unter lit. a)) ein Verstoß gegen das darin statuierte FRAND-Prozedere nicht vorgeworfen werden kann, haben sich die Beklagten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht lizenzwillig gezeigt (dazu insgesamt unter lit. b)). 281

a)

Die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, gehört zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht (EuGH, GRUR 2005, 764, Rn. 46 – Huawei / ZTE; BGH, GRUR 2020, 961, Rn. 69 – FRAND-Einwand). Die Klage eines marktbeherrschenden Patentinhabers, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann jedoch einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn und soweit sie geeignet ist, zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich bleiben (EuGH, ebd., Rn. 54 ff.; BGH, ebd., Rn. 68). 282

aa) 283

Vor diesem Hintergrund hat der EuGH dem Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu gewähren, Verpflichtungen auferlegt, die – sofern sie von diesem eingehalten werden – dazu führen, dass eine von diesem erhobene Klage auf Unterlassen oder Rückruf nicht als Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung anzusehen ist (EuGH, ebd., Rn. 55). Gleiches gilt für eine Klage, die auf die Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen oder auf deren Vernichtung gerichtet ist (BGH, ebd., Rn. 68; OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219, Rn. 220 – 284

Mobiles Kommunikationssystem).

Das Verhaltensregime des EuGH sieht vor, dass der Patentinhaber den angeblichen Verletzter „vor Erhebung der Klage“ (bzw. „vor der gerichtlichen Geltendmachung“) unter Angabe des fraglichen SEP sowie der Art und Weise der Verletzung hinzuweisen hat (EuGH, ebd., Rn. 62, 71). Hat der angebliche Patentverletzer daraufhin seine Lizenzbereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags unter FRAND-Bedingungen zum Ausdruck gebracht, hat der Patentinhaber – um sich nicht dem Vorwurf des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung auszusetzen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten (EuGH, ebd., Rn. 71). Aus diesem müssen insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung hervorgehen (a.a.O.). Dem vermeintlichen Patentverletzer obliegt es sodann, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren (EuGH, ebd., Rn. 65, 71). Nimmt der vermeintliche Verletzer das Angebot nicht an, kann er sich auf die rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht (EUGH, ebd., Rn. 66). Weiter hat der Patentbenutzer ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten (EuGH, ebd., Rn. 67). 285

bb) 286

Die EuGH-Rechtsprechung ist auch auf den hier vorliegenden Fall anwendbar. 287

Die Kammer vermag schon einen sachlichen Grund dafür, die Verhaltenspflichten des Inhabers eines Schutzrechts danach zu unterscheiden, ob das Schutzrecht Teil eines durch eine Normierungsorganisation gesetzten Standards ist (so die Konstellation in dem EuGH-Urteil in der Sache Huawei / ZTE), oder ob dieses „lediglich“ faktisch zu einem Standard erhoben worden ist (so die Konstellation in: BGH, NJW-RR 2009, 1947 – „Orange-Book-Standard“), nicht zu erkennen. Denn die Verhaltenspflichten resultieren aus der marktbeherrschenden Stellung, die wiederum an die tatsächlichen Marktgegebenheiten anknüpft – unabhängig davon, wie diese zustande gekommen sind. 288

Auf eine Entscheidung dieses Aspekts kommt es aber auch für den hier vorliegenden Fall nicht an. Denn die Konstellation, die den EuGH dazu veranlasste, dem Patentinhaber die näher beschriebenen Obliegenheiten aufzuerlegen (für einen normierten Standard essentielles Schutzrecht und Abgabe einer FRAND-Verpflichtungserklärung, vgl. EuGH, ebd., Rn. 49f.), sind auch hier gegeben. 289

Auch hier ist das Klagepatent zwingender Teil einer standardisierten Technik (dazu unter Ziff. IV., 1), die für den Smartphone-Markt (bzw. Tablet-Markt) eine Relevanz entfaltet. Unerheblich ist, dass es sich dabei nicht um einen – wie die Klägerin vorträgt – „Mobilfunkstandard“ handelt, das heißt der AAC-Standard nicht die Grundtechnologie der Sprachtelefonie betrifft. Der AAC-Standard bezieht sich auf sämtliche Endgeräte, für die die Audiodecodierung von Interesse ist. Zu solchen Endgeräten gehören auch Smartphones bzw. Tablets, weil die Erwartungshaltung des Endabnehmers dahingeht, Audioinhalte mit diesen abspielen zu können. Die Relevanz des Standards für die genannten Produkte erreicht auch eine solche, die als marktbeherrschend zu qualifizieren ist (dazu unter Ziff. 1., lit. b)). Dies ist auch gerade auf die Standardisierung zurückzuführen. Dem steht insbesondere nicht entgegen, dass die Marktbeherrschung dadurch zustande kommt, dass der AAC-Standard 290

eine Zertifizierungsvoraussetzung für das Android-Betriebssystem ist. Die Klägerin hat jedenfalls auf einen entsprechenden Vortrag der Beklagten, dass die Standardsetzung in dieser Art und Weise auf die Marktverhältnisse wirkte, und nicht etwa – was theoretisch denkbar ist – umgekehrt, die Standardsetzung eine Folge von Marktverhältnissen ist, in denen sich AAC bereits vor der Standardsetzung durchgesetzt hatte, nichts vorgebracht. Die Standardisierung wirkt so auch bei der Durchdringung des Smartphone- (bzw. Tablet)-Marktes fort. Dies berücksichtigend können die Marktverhältnisse nicht losgelöst von der Standardsetzung betrachtet werden).

Auch die weiteren Erwägungen, mit denen der EuGH dem Patentinhaber das Antragen eines FRAND-Angebots auferlegt hat, treffen auf die vorliegende Konstellation zu. Denn die Klägerin hat gegenüber ISO/IEC eine Erklärung abgegeben, Lizenzen an dem Klagepatent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen; und zwar unabhängig davon, über welches Endgerät die Audiowiedergabe erfolgt. Die von dem EuGH angenommene Erwartungshaltung, Nutzungsrechte an der standardmäßigen Lehre zu erhalten, ist mithin gleichermaßen gegenüber Herstellern von Mobiltelefonen begründet (zu diesem Aspekt allgemein auch: Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 368). 291

b)

Die Beklagten haben sich auf die Verletzungsanzeige der Klägerin (dazu unter lit. aa)) bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen bereit gezeigt, während auf Seiten der Klägerin ein Verhalten, welches die Annahme rechtfertigt, dass diese ihrerseits nicht (mehr) lizenzwillig ist, nicht vorliegt (dazu insgesamt unter lit. bb)). 292

aa) 293

Eine hinreichende Verletzungsanzeige liegt mit dem Schreiben vom 12.12.2016 (Anlage K1c) vor. 294

Da bei der Verletzungsanzeige „das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll“ (EuGH, ebd., Rn. 61), sind die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, der angegriffenen Ausführungsform und der vorgeworfenen Benutzungshandlung (im Sinne von §§ 9 f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich (BGH, GRUR 2020, 961, Rn. 85; OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 143 – Mobiles Kommunikationssystem). Die Verletzungsanzeige verlangt aber keine detaillierten (technischen und/oder rechtlichen) Erläuterungen – der andere Teil muss nur in die Lage versetzt werden – ggf. mit sachverständiger Hilfe – den Verletzungsvorwurf zu prüfen (BGH, a.a.O.; OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 385). Die Verletzungsanzeige dient dazu, dem hinsichtlich des Schutzbereichseingriffs ggf. noch gutgläubigen Benutzer die Gelegenheit zu geben, um die Erteilung einer aufgrund der FRAND-Erklärung jedem Interessenten zugesagten Benutzungserlaubnis nachzufragen (Kühnen, ebd., Rn. 387). Die Pflicht zur Selbstanzeige ist jedoch kein Selbstzweck. Sie ist deshalb dort entbehrlich, wo sie sich als nutzlose Förmelei darstellt, weil aufgrund der Gesamtumstände mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der Verletzungsbeklagte Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform hat und sein Berufen darauf, der Kläger habe ihm dies nicht angezeigt, als Rechtsmissbrauch erscheint (LG Düsseldorf, GRUR-RS 2018, 33825, Rn. 160; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 387). An das Vorliegen eines solchen Tatbestandes sind jedoch hohe Anforderungen zu stellen (Kühnen, a.a.O.). 295

Nach dieser Maßgabe gilt hier Folgendes: 296

(1) 297

Unbeschadet dessen, ob es nach dem Kontakt der Muttergesellschaft und XXX im Jahre 2005 und den Kontakten in dem Zeitraum zwischen 2007 – 2016 überhaupt noch eines Verletzungshinweises bedurfte, enthält das an die Muttergesellschaft gerichtete Schreiben vom 12.12.2016 (Anlage K1c) diejenigen Angaben, derer es bedurfte um der Muttergesellschaft der Beklagten eine Überprüfung des Verletzungsvorwurfs zu ermöglichen. 298

In dem Schreiben werden die Produkte, die nach Auffassung der Klägerin ihre Schutzrechte verletzen, allgemein in der Art beschrieben, dass es sich um sämtliche Endgeräte handele, die den AAC-Standard implementieren. Darüber hinaus werden in dem Schreiben beispielhaft XXX -Produkte genannt („XXX“,“XXX“). Neben einem pauschalen Verweis auf eine dem Schreiben beigefügte Liste der von der Klägerin gehaltenen AAC-relevanten Patente (vgl. Anlage K1c, S. 3f.), in der auch das hiesige Klagepatent erfasst ist, enthält das Schreiben weiter auch Claim Charts zu sieben dieser Patente, unter anderem zu dem Klagepatent. 299

Unschädlich ist, dass das Schreiben an die Muttergesellschaft der Beklagten und nicht an diese persönlich gerichtet war. 300

Sofern auf Seiten des Patentbenutzers sichergestellt ist, dass eine der Muttergesellschaft übersandte Verletzungsanzeige konzernintern an die jeweils betroffenen Tochtergesellschaften weitergeleitet wird, bedarf es keiner formalen Benachrichtigung sämtlicher Tochtergesellschaften (BGH, GRUR 2020, 961, Rn. 89 – FRAND-Einwand; OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 145 – Mobiles Kommunikationssystem; LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, Az.: 4a O 17/17, Rn. 207, zitiert nach BeckRS 2018, 35570; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn.386). 301

So ist es auch vorliegend. 302

Bereits die konzerninterne Zugehörigkeit rechtfertigt grundsätzlich die Annahme der Weiterleitung des Hinweises (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Weiter heißt es in dem Verletzungshinweis aber auch: 303

„Since communication of XXX has been directed to you, we address our licensing to you as well. Please note however, that our request is extended to all XXX group companies.“ (Anlage K1c, S. 2, 4. Abs.). 304

Weder die Muttergesellschaft noch die Beklagten sind zudem im Rahmen des hiesigen Prozesses dem Eindruck der Klägerin entgegengetreten, dass es sich bei der Muttergesellschaft um die für die Entscheidung über eine Lizenznahme zuständige Gesellschaft handelt. Vielmehr tragen die Beklagten selbst vor, die im Jahre 2020 von ihnen ausgehende Kommunikation sei von Herrn XXX in seiner Eigenschaft als General Counsel der „XXX“ geführt worden (Duplikschriftsatz vom 07.12.2020, S. 19, Rn. 73 – 75, Bl 294 GA). In dem von Herrn XXX verfassten Schreiben vom 25.03.2020 heißt es dann auch: 305

„ XXX („XXX “ or „we“) is the legal entity which is responsible for intellectual property and license management for all subsidiaries of XXX.“ (Anlage K-Kart12, S. 1, 2. Abs.). 306

(2) 307

308

Es ist unerheblich, dass die Beklagten die „von der Klägerin behauptete Korrespondenz“ aus dem Jahre 2016 sowie diejenige mit anderen Gesellschaften des Konzerns mit Nichtwissen bestreiten.

Diesem Bestreiten kommt nach Maßgabe von § 138 Abs. 4 ZPO keine prozessrechtliche Relevanz zu. 309

Nach der Wertung des § 138 Abs. 4 ZPO kann eine Erklärung mit Nichtwissen nur im Hinblick auf solche Tatsachen erfolgen, die außerhalb der eigenen Wahrnehmung der Partei liegen. Hat die Partei zu einer Tatsache kein aktuelles Wissen, treffen sie – soweit zumutbar und möglich – Informationspflichten, wobei insbesondere im eigenen Unternehmensbereich Erkundigungen einzuholen sind (BGH, GRUR 2002, 190 (191)). 310

Das trifft auf die Beklagten im vorliegenden Fall in besonderer Weise zu. Nach den Ausführungen unter Ziffer (1) besteht eine – zumindest konkludente – unternehmensinterne Abstimmung dahingehend, dass die Muttergesellschaft die Kommunikation über die Lizenznahme führt. Die Beklagten haben daher auch bei dieser im Hinblick auf die Lizenznahme betreffenden Tatsachen nachzufragen. Inwiefern ihre „internen Recherchen“ überhaupt geeignet waren, nähere Informationen zur Kommunikation mit der Klägerin und XXX in der Zeit nach Beendigung des Poollizenzvertrags im Jahre 2007 zu erhalten, und dass sie hierbei sämtliche Informationsquellen ausgeschöpft haben, ist ihrem pauschalen Vorbringen (vgl. Klageerwiderung, S. 25, Rn. 99, Bl. 149 GA) nicht zu entnehmen. Das Bestreiten der Beklagten erweist sich auch vor dem Hintergrund als mindestens zweifelhaft, als sie selbst sich – im Hinblick auf für sie günstige Tatsachen – auf Inhalte aus dem in Rede stehenden Schreiben stützen. So machen sie insbesondere geltend, die Klägerin habe der Muttergesellschaft damit den Abschluss einer bilateralen Lizenz in Aussicht gestellt. 311

bb) 312

Eine Lizenzwilligkeit auf Seiten der Beklagten ist nicht erkennbar. 313

Eine Gesamtbetrachtung ihres Verhaltens sowie desjenigen der Muttergesellschaft trägt vielmehr die Feststellung, dass diese zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen nicht bereit war und eine solche Bereitschaft auch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht entstanden ist. 314

(1) 315

Der BGH hat die Anforderungen an die nach der EuGH-Rechtsprechung erforderliche Lizenzwilligkeit des Nutzers in seiner jüngsten Rechtsprechung in den Urteilen FRAND-Einwand und FRAND-Einwand II dahingehend konkretisiert, dass sich der Nutzer seinerseits klar und eindeutig bereit erklären muss, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen (BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 57 – FRAND-Einwand II; ders., GRUR 2020, 961, Rn. 83 – FRAND-Einwand). Die fortdauernde Lizenzbereitschaft ist danach unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern (BGH, GRUR-RS 2020, 41776; Rn. 68 – FRAND-Einwand II). So kommt es auf die Lizenzbereitschaft auch dann an, wenn der Patentinhaber dem Nutzer bereits ein Lizenzangebot unterbreitet hat (BGH, ebd., Rn. 69), selbst wenn dieses im Wesentlichen vollständige Vertragsangebot noch nicht in jeder Hinsicht den Anforderungen des abzuschließenden Vertrags an faire, angemessene und nicht-diskriminierende Bedingungen der Nutzung der Vertragsschutzrechte entspricht 316

(BGH, ebd., Rn. 72 f.). Der Nutzer muss sich, jedenfalls dann, wenn er bis dahin keine Lizenzbereitschaft hat erkennen lassen, mit diesem in einer Weise auseinandersetzen, die erkennen lässt, dass er das Ziel verfolgt, alsbald zu einem beiderseits interessengerechten Ergebnis zu gelangen (a.a.O.).

Ein Verletzer, der mehrere Monate (in den vom BGH entschiedenen Fällen lagen Zeiträume von fast einem Jahr bzw. von mehr als einem Jahr zwischen dem Verletzungshinweis und der Reaktion des Nutzers) auf den Verletzungshinweis schweigt, gibt damit regelmäßig zu erkennen, dass ihm an einer Lizenznahme nicht gelegen ist (BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 88 – FRAND-Einwand II; ders., GRUR 2020, 961, Rn. 92 – FRAND-Einwand). Zwar ist auch einem zunächst lizenzunwilligen Nutzer bis zur Grenze der Verwirkung zuzugestehen, dass er lizenzbereit wird (BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 84 – FRAND-Einwand II). Es gilt aber, je länger der Nutzer mit der Geltendmachung seines Lizenzierungsanspruchs zugewartet hat, desto höhere Anforderungen sind an seine Mitwirkung bei der Herbeiführung eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen zu stellen (BGH, ebd., Rn. 60, 84, 90, 107f.). Eine nach Klageerhebung erklärte Lizenzbereitschaft ist in besonderer Weise im Hinblick auf einen tatsächlichen Lizenzwillen zu prüfen, weil es sich bei ihr auch lediglich um Verhalten handeln kann, mit welchem der Nutzer dem gerichtlichen Vorwurf fehlender Lizenzbereitschaft zu entgehen versucht, ohne ernsthaft an einer Lizenz interessiert zu sein (ähnlich für die dort entschiedene Fallkonstellation, allerdings im Hinblick auf ein von den Beklagten unterbreitetes Gegenangebot: BGH, ebd., Rn. 127 a. E.). An dieses Verhalten des Nutzers knüpft die Besorgnis, dass dieser allein eine Verzögerung der Vertragsverhandlungen bis zum Ablauf des Schutzrechts anstrebt, in besonderer Weise an (BGH, ebd., Rn. 67). 317

Aus den angeführten Gründen ist bei der Beurteilung der Lizenzwilligkeit nicht ausschließlich das Verhalten eines Nutzers im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in den Blick zu nehmen, sondern ist auch maßgeblich, wie sich dieser in der Vergangenheit gerierte. Vorzunehmen ist mithin eine Gesamtbetrachtung des Nutzerverhaltens. 318

(2) 319

Orientiert an dieser Rechtsprechung, die jedenfalls in dem hier vorliegenden Fall in keinem Widerspruch zu der EuGH-Rechtsprechung (dazu unter lit. a), aa)) steht (dazu unter Pkt. B., I., 2.), stellt sich das Verhalten der Beklagten bzw. XXX nicht als ein solches eines lizenzwilligen Nutzers dar. 320

Zu diesem Verhalten im Einzelnen: 321

(a) 322

Zu dem Verletzungshinweis vom 12.12.2016 (Anlage K 1c), in dem auch die Möglichkeit zum Abschluss eines bilateralen Vertrags eröffnet wurde (Anlage K1c, S. 2, 2. Abs.), äußerte sich XXX weder in schriftlicher noch in mündlicher Form. Auch hinsichtlich des auf den Verletzungshinweis folgenden Schreibens von XXX vom 13.04.2017 (Anlage K-Kart 10), mit welchem ein Angebot zum Abschluss eines Standardlizenzvertrags übersandt wurde, blieb eine Reaktion aus. 323

Die Kammer verkennt nicht, dass es vor der hier in Rede stehenden Kommunikation Anfang März zu einem persönlichen Treffen zwischen XXX und XXX kam und die genannten Parteien Ende April 2016 ein Telefonat führten – das Bestreiten dieser Kommunikation durch die Beklagten ist prozessrechtlich unerheblich (dazu unter lit. aa), (2)). Einerseits ist jedoch 324

zu dem Inhalt der Kommunikation hier nichts bekannt, weshalb die Kammer auch daraus für eine etwaige Lizenzwilligkeit von XXX nichts herzuleiten vermag. Zum anderen machten aber auch XXX,

„Although during March meeting, as well as through our past correspondence, XXX & XXX has not indicated its willingness to take a license for the AAC patent rights, we, […9.“ (Anlage K-Kart 9, Schreiben vom 23.03.2016, S. 1, 1. Abs.), 325

und die Klägerin, 326

„A template license agreement […] is available upon an indication that XXX is willing to enter into an AAC license agreement on FRAND terms. 327

XXX requests that XXX conclude a license for XXX ‘ AAC patents, thereby bringing an end to its unauthorized use of the XXX AAC patents.“ (Anlage K 1c, Schreiben vom 12.12.2016, S. 2, 2. Abs. a. E. und 3. Abs.), 328

deutlich, dass sie eine Lizenzwilligkeit von XXX bisher nicht erkennen konnten, und es insoweit eines eindeutigen Verhaltens bedurfte. 329

(b) 330

Erst über drei Jahre nach dem Verletzungshinweis, nach Kenntnisnahme von der hiesigen Klage, erklärte Herr XXX für XXX mit Schreiben vom 25.03.2020 erstmalig: 331

„[…], XXX hereby explicitly emphasizes to be continuously willing to take a license for the Patent under terms which are fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND).“ (Anlage K-Kart 12, S. 1, letzter Abs. a. E.). 332

Gleichwohl ist eine Lizenzwilligkeit der Beklagten nicht erkennbar. Vielmehr stellen sich der weitergehende Inhalt des Schreibens und das auf dieses folgende Verhalten der Muttergesellschaft bzw. der Beklagten aus der Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers als Fortsetzung eines auf die Verzögerung der Verhandlung gerichteten Verhaltens dar. 333

(aa) 334

In dem Schreiben vom 25.03.2020 (Anlage K-Kart12) äußerte sich die Muttergesellschaft verwundert darüber, dass die Klägerin ein konkretes Angebot noch nicht unterbreitet habe, 335

„As of yet, it is unclear to XXX why XXX did not submit a concrete license offer and why the correspondence was stalled until today. In this regards, it comes to XXX surprise that XXX disregarded both parties‘ past efforts and initiate a lawsuit against XXX subsidiaries in Germany and Europe“ (Anlage K-Kart12, S. 1, vorletzter Abs.). 336

Diese Einschätzung lässt sich mit dem Gang der Vertragsverhandlungen bis März 2020 nicht in Einklang bringen. Denn XXX hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine Lizenzbereitschaft in keiner Weise zum Ausdruck gebracht. Die Beklagten selbst tragen auch bezeichnenderweise keine vor diesem Zeitpunkt liegende Erklärung oder Handlung vor, denen eine Lizenzbereitschaft auf ihrer Seite zu entnehmen wäre und aufgrund derer sich die Klägerin zu einer Vertragsofferte hätte veranlasst sehen sollen. Die auf Seiten von XXX geäußerte Verwunderung ist vor diesem Hintergrund aus objektiver Empfängersicht nicht erklärlich. Das gilt umso mehr als es nicht zutrifft, dass XXX noch kein konkretes Vertragsangebot angetragen worden war. Denn XXX erhielt jedenfalls von XXX mit Schreiben vom 13.04.2017 337

(Anlage K-Kart10) das Exemplar eines Standardlizenzvertrags zugesandt, ohne dass XXX sich dazu verhalten hätte.

(bb) 338

Das Verhalten der Muttergesellschaft bzw. der Beklagten ist dann in der Folgezeit davon geprägt, dass sie einerseits von der Klägerin eine Vertragsofferte für eine bilaterale Lizenz fordern, ohne dass ein berechtigtes Interesse an einer solchen – in Abgrenzung zu einer Poollizenz – offengelegt wird (dazu unter lit. (aaa)), und sie andererseits Informationen über die Poollizenz verlangen, ohne dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser stattfindet (dazu unter lit. (bbb)). Dieses Verhalten zeigt die fortdauernde Lizenzunwilligkeit von XXX. 339

(aaa) 340

XXX forderte in diversen Schreiben, erstmals mit Schreiben vom 25.03.2020 (Anlage K-Kart12) sowie unter anderem mit Schreiben vom 17.08.2020 (Anlage B22; deutsche Übersetzung: Anlage B22a) und vom 03.11.2020 (Anlage B24; deutsche Übersetzung: Anlage B24a) sowie zuletzt mit E-Mail vom 15.03.2021 (Anlage B27), ein bilaterales Vertragsangebot von der Klägerin ein. Die Muttergesellschaft hat jedoch weder in den genannten Schreiben noch haben die Beklagten im Rahmen ihres Prozessvorbringens ein hinreichend konkretisiertes Interesse an einer bilateralen Lizenz erkennen lassen. 341

Von einem tatsächlich lizenzwilligen Nutzer wäre demgegenüber zu erwarten gewesen, dass dieser nach einem Zeitraum von über drei Jahren seit Kenntnisnahme von einer Poollizenz und der Möglichkeit zum Abschluss eines bilateralen Vertrags beide Alternativen bereits in gewissem Umfang gegeneinander abgewogen hat und auf der Grundlage spezifischer Konzernverhältnisse Angaben dazu macht, weshalb gerade eine bilaterale Lizenznahme vorzugswürdig ist. 342

(i) 343

Die Muttergesellschaft hat zu keinem Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen behauptet, dass von ihr lediglich die AAC-relevanten Patente der Klägerin genutzt werden. Vor dem Hintergrund, dass die „GMS“-Zertifizierung den AAC-Standard voraussetzt (dazu unter Ziff. 1, b), aa)), ist anzunehmen, dass die Muttergesellschaft grundsätzlich auf die gesamte AAC-Infrastruktur angewiesen ist. Dann aber erweist sich die Lizenznahme über einen Pool aus Sicht des Lizenzsuchers oftmals als zeit- und kostensparender, weil er die zur Nutzung des Standards erforderlichen Rechte aus einer Hand zu einheitlichen Konditionen erhält (LG Düsseldorf, GRUR-RS 2018, 33825, Rn. 223; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 493). Die Muttergesellschaft hatte schließlich auch bereits im Jahre 2005 eine Poollizenz genommen. Die Beklagten haben auch im Rahmen des hiesigen Verfahrens die FRAND-Gemäßheit des Poollizenzvertrags – jedenfalls bis zu ihrem Quadruplikschriftsatz vom 01.04.2021 (dazu unter lit. (bbb), (ii)) – nicht in Abrede gestellt. 344

(ii) 345

Dass die Muttergesellschaft sich demgegenüber im Hinblick auf den gesamten hier relevanten Standard für das Modell einer bilateralen Lizenznahme entschieden hat, ist nicht dargetan. 346

347

Die Muttergesellschaft hat, obwohl sie die Vorlage eines bilateralen Lizenzangebots bereits mit Schreiben vom 25.03.2020 (Anlage K-Kart12) und auch mit Schreiben vom 17.08.2020 (Anlage B22; deutsche Übersetzung: Anlage B22a) verlangte, erstmalig in dem Schreiben vom 03.11.2020 (Anlage B24; deutsche Übersetzung: Anlage B24a) ein irgendwie geartetes Interesse an einer bilateralen Vereinbarung näher beschrieben. In dem genannten Schreiben heißt es zu diesem Gesichtspunkt:

„Erstens ist es XXX grundsätzliche Geschäftspraxis, Lizenzen auf bilateraler Ebene zu nehmen. XXX engagiert sich in bilateralen Verhältnissen mit anderen XXX Mitgliedern. Der Verweis auf eine Poollizenz zwingt XXX dazu, Lizenzen zu nehmen und möglicherweise doppelt zu bezahlen, welche XXX bereits auf bilateraler Grundlage gewährt wurden. 348

Zweitens, eine bilaterale Lizenz zwischen XXX und XXX würde vollständig die angeblich unerlaubten Benutzung von XXX‘ Patenten abdecken und die Interessen beider Parteien vollständig befriedigen. 349

Drittens und wichtigstens, ist die Tatsache, dass XXX bilaterale Lizenzen an seinen AAC Patenten auf der Webseite https://www.XXX bewirbt und behauptet, bilaterale Lizenzen Wettbewerbern angeboten zu haben.“ (Anlage B24a, Hervorhebung diesseits). 350

Aber auch diese pauschalen Angaben lassen einen aus Sicht des Verhandlungspartners erforderlichen Bezug zu den Unternehmensverhältnissen der Muttergesellschaft, auf deren Grundlage ernsthafte Lizenzverhandlungen möglich sind, nicht erkennen. 351

(?) 352

Die Beklagten führen als ersten Gesichtspunkt für ihr Interesse an einem bilateralen Lizenzvertrag mit der Klägerin ihre Geschäftspraxis an. 353

Bisher ist es noch zu keinem Abschluss bilateraler Verträge mit anderen Inhabern von AAC-relevanten Patenten gekommen, obwohl Benutzungshandlungen von XXX seit 2007 (= Kündigung des mit der Muttergesellschaft bestehenden Poollizenzvertrags) im Raum stehen. Es liegt mithin ein erheblicher Zeitraum vor, innerhalb dessen die Muttergesellschaft Gelegenheit hatte, das von ihr beschriebene Lizenzmodell zu praktizieren. Als ein in diesem Sinne ergiebiger Vertrag kann auch nicht das Vertragsverhältnis der XXX mit „XXX“ erachtet werden. Denn dieses betrifft nicht die hier angeführte Lizenzierungspraxis der Muttergesellschaft, es betrifft vielmehr die für die TV-Sparte zuständigen Gesellschaften des Konzerns der Beklagten. Die Beklagten selbst führen dieses auch in dem hier in Rede stehenden Zusammenhang nicht an. 354

Auch haben weder die Muttergesellschaft noch die Beklagten solche Pool-Lizenzgeber namentlich benannt, mit denen sie sich zumindest in ernsthaften Lizenzverhandlungen befinden. Dieses Verhalten ist unter dem Gesichtspunkt der Lizenzwilligkeit umso fragwürdiger, als die Klägerin bereits mit Schreiben vom 05.10.2020 (Anlage B23; deutsche Übersetzung: Anlage B23a) offenlegte, dass sie keine Kenntnis davon habe, dass Vereinbarungen mit anderen Poollizenzgebern getroffen worden seien (ebd., S. 2, vorletzter Abs.). Jedenfalls nach dieser Äußerung der Klägerin wäre zu erwarten gewesen, dass die Muttergesellschaft ihr Interesse an einer bilateralen Lizenz in dem Schreiben vom 03.11.2020 weiter konkretisiert. Der Kammer ist zwar bekannt, dass die Muttergesellschaft dem Poolmitglied „XXX“ im März 2021 ein Vertragsangebot unterbreitet hat, aber auch dieses ist nach Würdigung der Kammer in den „XXX“-Verfahren vor dem Hintergrund eben dieser Verfahren zu sehen und nicht von einer tatsächlichen Lizenzbereitschaft der 355

Muttergesellschaft getragen (vgl. Urt. der Kammer vom selben Tag, Az.: 4b O 23/20 und 4b O 49/20).

Hierbei verbleibt es auch, nachdem die Beklagten im Hinblick auf ihr Interesse an einer bilateralen Lizenz in ihrem Quadruplikschriftsatz vom 01.04.2021 (!) nunmehr erstmalig (!) anbringen, ihnen sei an einer bilateralen Vertragspraxis gelegen, um „ihr eigenes Portfolio im Rahmen von Kreuzlizenzen einzusetzen“. Denn auf Vertragsabschlüsse oder konkreten Verhandlungen der Muttergesellschaft, in denen ihre so beschriebene bilaterale Lizenzpraxis einen Niederschlag findet, wird auch insoweit nicht verwiesen. Der zwischen der Klägerin und XXX am Ende des Jahres 2020 abgeschlossene bilaterale Lizenzvertrag, der das 3G/ LTE-SEP Portfolio der Klägerin betrifft, kann in diesem Zusammenhang nicht angeführt werden. In Rede steht hier die Lizenznahme an Patenten, die für den AAC-Standard wesentlich sind, von diesem sind der 3G- bzw. LTE-Standard zu unterscheiden. Die Kammer vermag aus dem Lizenzverhältnis über den genannten Standard nichts für die Bereitschaft der Lizenznahme der Muttergesellschaft an den für den AAC-Standard wesentlichen Patenten bzw. für ihre bilaterale „Lizenzpraxis“ in diesem Zusammenhang herzuleiten. 356

(?) 357

Der zweite Gesichtspunkt, den die Beklagten für den Abschluss einer bilateralen Lizenz in dem Schreiben aus November 2020 vorbringen, lässt kein konkretes Interesse der Muttergesellschaft erkennen. Der zitierte Passus gibt vielmehr das Ergebnis einer von der Muttergesellschaft vorgenommenen Abwägung wieder, wonach sich eine bilaterale Lizenz auch aus Sicht der Klägerin als interessengerecht erweist. 358

(?) 359

Der Eindruck der Lizenzunwilligkeit der Beklagten in diesem Zusammenhang verstärkt sich noch dadurch, dass diese als dritten und „wichtigsten“ Grund für eine bilateralen Lizenznahme anführen, dass die Klägerin mit anderen Lizenznehmern solche Verträge abgeschlossen habe. Dies mag zwar unter Diskriminierungsgesichtspunkten grundsätzlich zutreffend sein, mutet aber vor dem Hintergrund des bereits dargestellten Verhaltens von XXX als formal geprägter Einwand an, der an eigene Interesse des Nutzers nicht anknüpft. Ein Fördern der Vertragsverhandlung kann deshalb darin nicht erblickt werden, der Einwand verzögert sie vielmehr weiter. 360

Insbesondere die mit diesem Einwand verbundene Schlussfolgerung der Muttergesellschaft, wonach jegliches Lizenzangebot für XXX AAC-Patente nur dann FRAND-gemäß sein könne, wenn es auf bilateraler Ebene gemacht werde, zeigt, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Lizenzgebührensystemen von Pool- und Portfoliolizenz tatsächlich nicht stattfindet. Die Schlussfolgerung ist so nicht nachvollziehbar. Eine „Gesetzmäßigkeit“ derart, dass die Existenz des einen Lizenzmodells zur FRAND-widrigkeit des anderen führt, gibt es nicht. Vielmehr ist auch ein Nebeneinander zweier Lizenzsysteme denkbar, die sich beide als FRAND-gemäß erweisen. Unbeschadet der Frage, ob dies im Ergebnis auf die hier in Rede stehenden Lizenzvarianten zutrifft, spricht dafür, dass grundsätzlich auch im vorliegenden Fall – in Abhängigkeit zu den jeweiligen Unternehmensverhältnissen des Lizenzsuchers – entweder die Pool- oder die Portfoliolizenz in Betracht kommt, die Tatsache, dass beide Lizenzformen in der Vergangenheit von Lizenznehmern gewählt worden sind. 361

(bbb) 362

363

Die Muttergesellschaft bzw. die Beklagten, die ohnehin für sich in Anspruch nehmen, dass sie eine bilaterale Lizenznahme vorziehen, lassen auch eine hinreichende inhaltliche Auseinandersetzung mit dem der Muttergesellschaft im April 2017 angebotenen Poollizenzvertrag nicht erkennen.

(i) 364

In einem an XXX gerichteten Schreiben vom 17.08.2020 (liegt nicht vor) erklärte XXX, dass weiterhin auch eine Lizenznahme über den AAC-Pool geprüft werde, ohne dass dann jedoch die Lizenznahme über den Pool erkennbar vorangetrieben worden ist. 365

(?) 366

XXX forderte von XXX zunächst ein neues Vertragsangebot im Hinblick darauf, dass sich der Vertrag seit 2016 (XXX erhielt bereits mit Schreiben vom 03.02.2016, Anlage K-Kart 8, ein Exemplar des Standardlizenzvertrags) geändert haben könnte. Unbeschadet dessen, dass die Klägerin insoweit vorträgt, dass das Pool-Programm mit XXX zuletzt in einem persönlichen Gespräch im Jahre 2019 erörtert wurde, stellt sich dies auch deshalb als Ausdruck einer angestrebten Verzögerung dar, weil XXX spätestens seit dem Schreiben von XXX vom 13.04.2017 darüber in Kenntnis war, dass weitergehende Informationen über den Pool auch im Internet abrufbar sind (Anlage K-Kart 10, S. 3 a. E.). Auf der Internetseite sind insbesondere Informationen zu Lizenzgebern, Lizenznehmern sowie die aktuelle Lizenzgebührentabelle erhältlich (vgl. Auszug des Internetauftritts Anlage K 1b). Von einem lizenzwilligen Nutzer, der mehrere Jahre mit einer Stellungnahme zugewartet hat, ist zu erwarten, dass er sich soweit wie möglich Kenntnisse über die Umstände verschafft, die sich seit dem ihm unterbreiteten Vertragsangebot geändert haben können. Das gilt vor allem deshalb, weil sein dahingehendes Informationsbedürfnis allein deshalb besteht, weil eine Reaktion seinerseits innerhalb einer angemessenen Frist ausgeblieben ist. 367

(?) 368

Weiter verlangte XXX nach über drei Jahren des Abwartens Darlegungen zum „inkrementellen Wert“ der Poollizenz. XXX war es jedoch aufgrund des Vertragsverhältnisses der Muttergesellschaft im Jahre 2005 möglich als Lizenzsucher, der sich nicht zum ersten Mal intensiv mit der Poollizenz und dem AAC-Standard befasste, an dem Verhandlungsprozess über das bloße Fordern von Angaben über den „inkrementellen“ Wert des Portfolios hinaus mitzuwirken; und zwar auch dann, wenn man berücksichtigt, dass sich die Poolstruktur seither umfangreich geändert hat. In diesem Zusammenhang fällt insbesondere auf, dass die Lizenzgebühren in dem Vertrag aus dem Jahre 2005 höher lagen (Stücklizenzgebühr zwischen USD XXX und USD XXX abhängig von jährlicher Absatzmenge) als die mit dem Standardlizenzvertrag nunmehr angebotenen Gebühren, die Anzahl der lizenzierten Poolpatente indes deutlich geringer war (XXX Patente). Weiter ist zu berücksichtigen, dass gerade die Mitwirkung des Nutzers bei der Ermittlung der angemessenen Lizenzgebühr eine besondere Bedeutung erlangt, insbesondere weil eine solche regelmäßig nicht objektiv feststeht, sondern nur als Ergebnis ausgehandelter Marktprozesse erfassbar ist (BGH, GRUR 2020, 961, Rn. 81). Verschließt sich der Nutzer hinsichtlich dieses bedeutsamen Aspekts einer Diskussion, bringt dies die Verhandlungen mithin jedenfalls zum Erliegen. Schließlich ist der Nutzer selbst am besten in Kenntnis über seine wirtschaftlichen Verhältnisse und kann Angaben dazu machen, in welcher Größenordnung ihm eine Lizenznahme unter Berücksichtigung seiner Wettbewerbsfähigkeit möglich ist. 369

(?) 370

Die Kammer deutet auch die Aufforderung der Muttergesellschaft gegenüber XXX, bereits abgeschlossene Lizenzverträge vorzulegen, nicht als Ausdruck der erforderlichen konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Poolangebot – was die Beklagten hier geltend machen. Die Aufforderung fügt sich vielmehr in das auch im Übrigen passive Verhalten der Beklagten ein. Dabei kann dahinstehen, ob und in welchem Umfang der Klägerin nach der bisherigen Rechtsprechung die Vorlage etwaiger Verträge oblag. Jedenfalls entbindet eine solche Obliegenheit auf Seiten des Patentinhabers den über mehrere Jahre abwartenden Nutzer nicht davon, nunmehr das seinerseits Mögliche zu tun, um die Vertragsverhandlungen voranzubringen. 371

(ii) 372

Auch das Prozessvorbringen der Beklagten lässt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Poollizenzvertrag nicht erkennen. Vielmehr spricht auch dieses dafür, dass es an der Lizenzwilligkeit von XXX fehlt. 373

Die Beklagten haben sich im Rahmen des hiesigen Prozesses erstmals acht Tage vor der mündlichen Verhandlung mit ihrem Quadruplikschriftsatz vom 01.04.2021 gegen die FRAND-Gemäßheit des der Muttergesellschaft angebotenen Poollizenzvertrags gewandt und geltend gemacht, dieser diskriminiere sie gegenüber anderen Lizenznehmern sachwidrig. Weitergehender Vortrag sei ihnen, so die Beklagten weiter, nicht möglich, da XXX durch ein (vor dem Hintergrund der vor der hiesigen Kammer unter den Aktenzeichen 4b O 23/20, 4b O 48/20 und 4b O 49/20 geführten Verfahren abgeschlossenen) Geheimhaltungsabkommen mit XXX und dem Poollizenzgeber „XXX“ gebunden sei. Auf das der Klägerin am 29.03.2021 angetragene Ansinnen, die Lizenzverträge in das hiesige Verfahren einzuführen, habe diese nicht angemessen reagiert und so eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den abgeschlossenen Poollizenzverträgen in der mündlichen Verhandlung vom 01.04.2021 nicht ermöglicht. 374

Diese Umstände vermögen jedoch die bis dahin fehlende Auseinandersetzung von XXX mit dem angebotenen Poollizenzvertrag nicht zu rechtfertigen. 375

Denn ein Nutzer, der 12 Tage vor der mündlichen Verhandlung beginnt, Maßnahmen zu ergreifen, um die FRAND-Gemäßheit inhaltlich erörtern zu können, dokumentiert so – jedenfalls bei Berücksichtigung des übrigen hier bereits geschilderten Verhaltens – seine Lizenzunwilligkeit 376

Die Klägerin hat, ohne dass die Beklagten dem entgegengetreten sind, in der mündlichen Verhandlung zu Recht darauf hingewiesen, dass das hier in Rede stehende Geheimhaltungsabkommen im Herbst 2020 abgeschlossen worden ist. Die Vorlage der Verträge erfolgte – was aufgrund der hier anhängigen „XXX“-Verfahren gerichtsbekannt ist – Ende des Jahres 2020. Spätestens ab diesem Zeitpunkt konnten die Beklagten etwaige aus ihrer Sicht für die Diskriminierung interessante Tatsachen ebenso erkennen, wie den Umstand, dass sie diese nicht ohne weiteres in das hiesige Verfahren einführen konnten. Gleichwohl blieben sie untätig, wirkten insbesondere nicht ihrerseits zu diesem frühestmöglichen Zeitpunkt auf den Abschluss eines NDA mit der Klägerin hin. 377

Ein frühes Bemühen der Muttergesellschaft lässt sich auch nicht dem Schreiben vom 03.11.2020 (Anlage B24; deutsche Übersetzung: Anlage B24a) entnehmen. In diesem heißt es zwar: 378

379

„Wir sind bereit, ein NDA abzuschließen, für den Fall, dass XXX ein solches für erforderlich hält bevor es angeforderten (sic!) Dokumente zur Verfügung stellt.“

Ein darüber hinaus gehendes Hinwirken der Muttergesellschaft auf ein solches NDA ist jedoch in der Folgezeit nicht erkennbar. Insbesondere ist die Muttergesellschaft ihrerseits nicht mit dem Entwurf eines solchen an die Klägerin herangetreten. 380

(c) 381

Ausgehend von dem bisher erörterten Verhalten der Muttergesellschaft kann bei der gebotenen Gesamtwürdigung auch das von dieser unterbreitete Gegenangebot vom 01.04.2021 (Anlage B29) nicht als Ausdruck einer nunmehr vorhandenen Lizenzbereitschaft gewertet werden. 382

Das gilt unabhängig von der Frage, ob sich dieses als in jeder Hinsicht FRAND-gemäß erweist. Die Muttergesellschaft konnte jedenfalls nicht annehmen, dass mit dem Gegenangebot das Zustandekommen eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen – eine entsprechende Bereitschaft des Patentinhabers vorausgesetzt – sachgerecht gefördert werden konnte (vgl. dazu allg. auch: BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 71 und ähnlich Rn. 116), es sich dabei mithin um eine geeignete Verhandlungsgrundlage handelte. 383

(aa) 384

Die Vertragsbedingungen des Gegenangebots sind an dem Lizenzvertrag orientiert, den die Klägerin mit der Muttergesellschaft Ende des Jahres 2020 über das 3G/LTE-SEP Portfolio der Klägerin abgeschlossen hat. 385

Ziffer 3.1 des Gegenangebots, das eine Laufzeit von fünf Jahren vorsieht, regelt die Zahlung einer pauschalen Lizenzsumme in Höhe von USD XXX bis zum XXX. 386

Zu dieser Summe gelangt XXX ausgehend von den Lizenzraten, die der AAC-Pool von XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX vorsieht, wobei Volumenrabatte abgezogen werden. So ermittelt XXX eine Stücklizenz in Höhe von USD XXX. Diese wird mit dem Anteil multipliziert, den die Patente der Klägerin an dem AAC-Pool haben – diesen Wert gibt XXX mit XXX % an –, sowie mit der Anzahl der über die Vertragslaufzeit zu erwartenden Absatzzahlen von XXX. Bei der zu erwartenden Absatzmenge nimmt XXX eine Prognose anhand von Daten des Brancheninformationsdienstleisters „International Data Corporation“ (im Folgenden: IDC) für das Jahr 2020 vor, die mit XXX verkauften Einheiten angegeben wird. 387

Bei rechtzeitiger Zahlung der Pauschallizenzgebühr wird XXX ausweislich Ziffer 2.1 des Gegenangebots von Ansprüchen, die wegen des Vertriebs AAC-fähiger Produkte vor Inkrafttreten des Vertrags entstanden sind, freigestellt. 388

(bb) 389

Das so beschriebene Gegenangebot ist als Verhandlungsgrundlage nicht geeignet. 390

Hiergegen spricht bereits die Tatsache, dass die Muttergesellschaft dieses ohne erkennbaren Grund erst acht Tage vor der mündlichen Verhandlung, nämlich am 01.04.2021, unterbreitet hat. Die Beklagten selbst tragen vor, das Gegenangebot sei „auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen“ erstellt. Es ist deshalb nicht ersichtlich, weshalb dieses der Klägerin erst unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung angetragen worden ist. 391

392

Weiter sieht das Gegenangebot die Freistellung von vor Inkrafttreten des Vertragsschlusses liegenden Benutzungshandlungen vor, ohne dass die Muttergesellschaft (oder die Beklagten im Rahmen des hiesigen Verfahrens) offenlegt, in welcher Größenordnung sich die in der Vergangenheit erzielten Absatzmengen bewegen. Auch führt sie keine Begründung dafür an, weshalb eine vollumfängliche Freistellung erfolgen soll. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass allein für die drei Jahre vor Klageerhebung Absatzmengen für Mobiltelefone von XXX in Rede stehen (vgl. Protokoll zur Sitzung vom 09.04.2021, S. 3, 2. Abs., Bl. 414 GA).

Letztlich geht die in dem Gegenangebot angesetzte Pauschallizenzsumme auf IDC-Zahlen zurück, die nicht valide sind. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vom 09.04.2021 vorgetragen, ihr würden gegenüber den von der Muttergesellschaft auf Grundlage von IDC-Daten mit XXX angegebenen veräußerten Einheiten IDC-Zahlen vorliegen, die allein für Mobiltelefone (ohne die mit der hiesigen Klage ebenfalls angegriffenen „Tablets“) XXX veräußerte Einheiten ausweisen würden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Muttergesellschaft als Antragende in der Pflicht ist, ihr Gegenangebot plausibel zu machen. In diesem Zusammenhang ist sie auf eine Auseinandersetzung über IDC-Zahlen nicht „angewiesen“, sie ist vielmehr in der Lage, die Richtigkeit derselben anhand ihrer tatsächlichen Verkaufszahlen zu ermessen, und diese Information in die Vertragsverhandlungen einzubringen. Dies ist indes nicht geschehen. 393

(d) 394

Die hier gestellten hohen Anforderungen an die Lizenzwilligkeit der Muttergesellschaft sind schließlich auch nicht deshalb überhöht, weil sich die Klägerin ihrerseits zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen nicht bereit zeigte. 395

Die Verhaltenspflichten des Nutzers im Rahmen des Verhandlungsprozederes hängen nach dem von dem BGH aufgestellten Maßstab davon ab, was nach den üblichen und anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und den Geboten von Treu und Glauben von diesem erwartet werden kann. Insbesondere im Falle eines offensichtlich FRAND-Bedingungen nicht entsprechenden Lizenzangebots des Patentinhabers, das sich bei objektiver Wertung als nicht ernst gemeint und damit als Weigerung darstellt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, kann als Reaktion eines ernsthaft um eine Lizenz nachsuchenden Nutzers der Erfindung die Darlegung genügen, aus welchem Grund das Angebot offensichtlich FRAND-Bedingungen nicht entspricht (BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 71 – FRAND-Einwand II). 396

Auch bei der danach gebotenen Berücksichtigung des Verhaltens der Klägerin ist es indes vorliegend gerechtfertigt, die Lizenzwilligkeit der Beklagten bzw. von XXX an dem Maßstab, wie unter lit. (a) – lit. (c) erörtert, zu messen. Denn die Klägerin hat sich im Rahmen der Vertragsverhandlungen nicht in dem soeben beschriebenen Sinne lizenzunwillig gezeigt. 397

(aa) 398

Der Klägerin kann es unter Missbrauchsgesichtspunkten nicht vorgeworfen werden, dass diese auf die Aufforderungen der Muttergesellschaft, ein bilaterales Lizenzangebot zu unterbreiten, ein solches nicht vorgelegt hat. 399

Mit dem Poollizenzvertrag liegt der Muttergesellschaft jedenfalls ein Vertragsangebot vor, das in dieser Form von anderen Marktteilnehmern akzeptiert worden ist. Diese Tatsache entfaltet jedenfalls eine gewisse Indizwirkung für die Angemessenheit der darin festgelegten 400

Vertragsbedingungen (LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, Az.: 4a O 17/17, Rn. 269, zitiert nach BeckRS 2018, 35570; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 262, 521). Damit ist jedenfalls eine Möglichkeit eröffnet, Zugang zu der Technik zu erlangen, die eine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Die Beklagten haben demgegenüber nicht aufgezeigt, weshalb sie für ein wettbewerbsfähiges Anbieten der Produkte einer bilateralen Vereinbarung bedürfen.

Etwas anderes gilt auch nicht deshalb, weil die Klägerin mit Schreiben vom 12.12.2016 (Anlage K1c) die grundsätzliche Möglichkeit zum Abschluss eines bilateralen Lizenzvertrags gegenüber der Muttergesellschaft kundgetan hat. Eine rechtliche Bindungswirkung entfaltet diese Mitteilung nicht. Vielmehr hat die Klägerin damit auf ihre grundsätzlich bestehende Lizenzvertragspraxis Bezug genommen, die sie auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung derart beschrieben hat, dass sie bilaterale Lizenzen an Lizenznehmer vergebe, die bereits mit anderen Lizenzgebern in bilateralen Vertragsbeziehungen stehen, oder denen gegenüber sich eine Poollizenz aus anderen Gründen als unangemessen erweist. Ein entsprechendes Interesse aber hat die Muttergesellschaft – wie unter lit. (b), (bb), (aaa) ausgeführt – nicht offengelegt. Es steht der Lizenzwilligkeit der Klägerin auch deshalb nicht entgegen, dass sie der Muttergesellschaft – anders als von dieser gefordert – keine bilateralen Lizenzverträge vorgelegt hat. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass sich auch etwaige Vorlage- und Erläuterungspflichten danach richten, was dem Patentinhaber vor dem Hintergrund des Verhaltens des Nutzers nach den geschäftlichen Gepflogenheiten als nächster Verhandlungsschritt zu erwarten ist (BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 58 – FRAND-Einwand II ; ders., GRUR 2020, 961, Rn. 76, Rn. 79 – FRAND-Einwand; zuvor bereits ähnlich: LG Düsseldorf, GRUR-RS 2020, 12599, Rn. 158, 165; ebd., GRUR-RS 2018, 33825, Rn. 210; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 426 und Rn. 527). 401

Auch soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang eine Entscheidung des hiesigen Landgerichts anführen, folgt daraus für den hier vorliegenden Sachverhalt nichts anderes. Denn auch darin heißt es, dass eine etwaige Wahlfreiheit des Lizenzsuchers nicht unbegrenzt bestehe, er vielmehr sachliche Gründe vorzubringen habe, wenn er eine anderer Lizenzierung als die ihm vorgeschlagene, begehre (LG Düsseldorf, Urt. v. 08.01.2019, Az.: 4c O 12/17, Rn. 400, zitiert nach juris). Dies aber hat die Muttergesellschaft vorliegend gerade nicht getan, was ihrer Lizenzwilligkeit entgegensteht (dazu unter lit. (b), (aaa)). 402

(bb) 403

Es ist auch bereits dargestellt worden, dass es nicht der Klägerin anzulasten ist, dass sich die Beklagten an einer inhaltlichen Auseinandersetzung über die FRAND-Gemäßheit der Poollizenz im Rahmen des hiesigen Verfahrens gehindert sehen (dazu unter lit. (b), (bbb), (ii)). 404

Hier sei lediglich noch ergänzend ausgeführt, dass es der Klägerin insbesondere nicht vorgeworfen werden kann, dass sie auf die Erklärung der Beklagten vom 29.03.2021, den Inhalt der bereits abgeschlossenen Lizenzverträge in das hiesige Verfahren einführen zu wollen, nicht in das NDA mit „XXX“ eintrat bzw. ein Geheimhaltungsabkommen nicht binnen einer Zeit unterzeichnete, die eine Erörterung der Verträge in der mündlichen Verhandlung vom 09.04.2021 ermöglichte. 405

Die Einbeziehung der Klägerin in das zwischen „XXX“, der Muttergesellschaft und XXX abgeschlossene NDA war, wie diese in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar dargetan hat (vgl. Protokoll zur Sitzung vom 09.04.2021, S. 2f. unten – S. 3, Bl. 413f GA), nicht möglich, da dieses auch die bilateralen Vereinbarungen umfasste, die „XXX“ mit Dritten abgeschlossen hatte. Die Kammer sieht auch deswegen keine Möglichkeit, die Akten der 406

genannten Verfahren hier beizuziehen. Insoweit erweist sich – was die Beklagten geltend machen – auch die von dem hiesigen Verfahren separate Betrachtung der „XXX“-Verfahren nicht als „künstlich“, sondern vielmehr aus Gründen des Schutzes geheimhaltungsbedürftiger Informationen geboten.

Sofern die Klägerin weiter vorträgt, die Unterzeichnung eines gesonderten Geheimhaltungsabkommens habe dann einen Zeitraum bis zum 08.04.2021 in Anspruch genommen, erscheint der Kammer dieser Zeitraum unter Missbrauchsgesichtspunkten nicht unangemessen. 407

(e) 408

In der Gesamtschau zeigt sich mithin vorliegend ein Nutzerverhalten, das zunächst dadurch geprägt ist, Versuche zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen schlicht zu ignorieren. Eine Reaktion erfolgte überhaupt erst nach Erhebung der hiesigen Klage, wobei es auch insoweit in der Folgezeit an konstruktiven Mitwirkungshandlungen, die auf das Zustandekommen eines Lizenzvertrags gerichtet sind, fehlt. Dies berücksichtigend bedurfte es – entsprechend der Anforderungen des BGH – auf Nutzerseite besonderer Anstrengungen, den Abschluss eines Lizenzvertrags zu fördern, und so zum Ausdruck zu bringen, dass – was einem Nutzer grundsätzlich zugestanden sein muss – eine Lizenzbereitschaft nunmehr entstanden ist. Solche Anstrengungen kommen indes hier in dem Gegenangebot vom 01.04.2021 nicht zum Ausdruck, weshalb XXX auch im Schluss der mündlichen Verhandlung noch als lizenzunwillig erachtet werden muss. Der Klägerin kann demgegenüber ein Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung derart, dass sie sich nicht hinreichend bemüht hat, einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzter den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen, nicht vorgeworfen werden (zu diesem Maßstab allgemein: BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 53 – FRAND-Einwand II). 409

B

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht weder bei Berücksichtigung des Vorlagebeschlusses der ebenfalls mit Patentverletzungsverfahren befassten 4c. Zivilkammer des hiesigen Gerichts (Beschl. v. 26.11.2020, Az.: 4c O 17/19, zitiert nach juris) (dazu unter Ziff. I.) noch vor dem Hintergrund des laufenden Rechtsbestandsverfahrens (dazu unter Ziff. II.) eine Veranlassung. 410

I. 411

Die Kammer sieht von einer Aussetzung der Verhandlung analog § 148 ZPO ab. 412

Erwägungen zu einer Aussetzung der Verhandlung sind vorliegend deshalb geboten, weil die Frage, wie die Lizenzwilligkeit in dem Fall zu beurteilen ist, in dem der Nutzer auf einen Verletzungshinweis hin für längere Zeit schweigt, auch Gegen-stand einer an den EuGH gerichteten Vorlagefrage ist (vgl. LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020, Az.: 4c O 17/19, Vorlagefrage unter Pkt. B., Ziff. 2., lit. a), zitiert nach juris). In einem Fall, in dem – wie hier – die Entscheidung des Rechtsstreits von der Beantwortung einer in einem anderen Verfahren dem EuGH vorgelegten Rechts-frage abhängig ist, kommt eine Aussetzung der Verhandlung analog § 148 ZPO in Betracht (BGH, BeckRS 2012, 4329, Rn. 8f.). 413

414

Die Kammer übt das ihr zustehende Ermessen derart aus, dass sie von einer Aus-setzung, die auch von den Parteien nicht angeregt worden ist, absieht.

1.

Im Ausgangspunkt orientiert sich die Kammer dabei an der aus Art. 267 Abs. 2 AEUV hervorgehenden Wertung. 415

Eine Orientierung an dieser Vorschrift ist sachgerecht, weil die Kammer ohne das genannte Vorabentscheidungsgesuch der Schwesterkammer in dem Verfahren mit dem Aktenzeichen 4c O 17/19 selbst die Entscheidung zu treffen hätte, ob sie eine Vorlage an den EuGH veranlasst. 416

Nach der genannten Vorschrift trifft das erstinstanzliche Gericht grundsätzlich keine Vorlagepflicht. Etwas anderes gilt nur in dem – hier nicht einschlägigen Fall – in dem das nationale Gericht eine Vorschrift des Unionsrechts oder eine sonstige Handlung eines Unionsorgans für ungültig erachtet und außer Anwendung lassen will (Wegener, in: Callies/ Ruffert, EUV/ AEUV, Kommentar, 5. Auflage, 2016, Art. 267 AEUV, Rn. 29). 417

2.

Die Kammer kann nicht erkennen, dass – was für eine Aussetzung sprechen könnte – der in der höchstrichterlichen nationalen Rechtsprechung entwickelte Maßstab für die Beurteilung der Lizenzwilligkeit vorliegend zwingend zu einem anderen Ergebnis führt, als nach den Anforderungen, die in der oberlandes- und landgerichtlichen Rechtsprechung bisher an die Lizenzwilligkeit gestellt worden sind. 418

Auch nach der bisherigen Rechtsprechung ist es für die Annahme der Lizenzwilligkeit auf Seiten des Nutzers nicht als ausreichend erachtet worden, dass dieser seine grundsätzliche Lizenzwilligkeit zu Beginn der Vertragsverhandlungen einmalig erklärt, diese jedoch in den sich dann anschließenden Vertragsverhandlungen keinen Niederschlag in seinem tatsächlichen Verhalten findet. Die Bereitschaft zur Lizenznahme muss die Vertragsverhandlungen vielmehr stetig begleiten und darin einen Ausdruck finden, dass der Nutzer, auch wenn er nach den Anforderungen des EuGH zunächst nicht in der Pflicht zur Unterbreitung eines FRAND-gemäßen Angebots steht, an dem Zustandekommen eines Lizenzvertrags konstruktiv mitwirkt (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 161 – Mobiles Kommunikationssystem; LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020, Az.: 4c O 17/19, Rn. 34, zitiert nach juris; ebd., GRUR-RS 2020, 12599, Rn. 309f.; LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, Az.: 4b O 5/17, Rn. 143 ff., zitiert nach BeckRS 2018, 38605). 419

Ein Unterschied zu dem unter Punkt A., Ziff. VIII., 2., b), bb), (1) dargestellten Verständnis, das der BGH in den Entscheidungen FRAND-Einwand und FRAND-Einwand II hat erkennen lassen, zu der bisherigen Rechtsprechung ist insoweit festzustellen, als an die Lizenzierungsbitte keine hohen inhaltlichen Anforderungen gestellt worden sind. Der Nutzer muss danach lediglich eine grundsätzliche (allgemeine) Bereitschaft zur Lizenznahme in Form einer eindeutigen, jedoch ergebnisoffenen Verhandlungsbereitschaft, ggf. auch konkludent, erkennen lassen (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 152, Rn. 160, Rn. 165 und Rn. 171 ff. – Mobiles Kommunikationssystem; zuletzt: LG Düsseldorf, Beschl. v. 420

26.11.2020, Az.: 4c O 17/19, Rn. 34, zitiert nach juris).

Aber auch ausgehend von einem Verständnis der Lizenzwilligkeit in dem beschriebenen allgemeineren Sinn sind bei dem hier vorliegenden Sachverhalt Zweifel an der Bereitschaft der Beklagten bzw. von XXX zum Abschluss eines Lizenzvertrags begründet. 421

Denn auch nach einer „weniger strengen“ Auffassung ist nicht allein an dem – vermeintlich eindeutigen Wortlaut – einer ausdrücklichen Lizenzierungsbitte zu haften, die hier überhaupt erstmals mit den Schreiben vom 25.03.2020 (Anlage K-Kart12) geäußert worden ist. Vielmehr muss auch eine solche Erklärung bei Berücksichtigung der diese begleitenden Umstände als ernsthafte Bekundung eines – wenn auch zunächst allgemeineren – Lizenzwillens verstanden werden können (zuletzt: LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020, Az.: 4c O 17/19, Rn. 35 a. E., zitiert nach juris). Das unter Punkt A., Ziff. VIII., 2., b), bb), (2) dargestellte Verhalten der Beklagten und der Muttergesellschaft ist indes auch geeignet, Zweifel an der Ernsthaftigkeit einer solchen allgemeinen Lizenzbereitschaftserklärung zu begründen. 422

3.

Bei der Ausübung ihres Ermessens hat die Kammer weiter berücksichtigt, dass die Laufzeit der Schutzdauer für das hiesige Klagepatent im April 2023 endet, und dass der BGH die Notwendigkeit einer erneuten Vorlage mit Blick auf die von ihm an die Lizenzwilligkeit gestellten Anforderung selbst geprüft und insoweit von einer Vorlage abgesehen hat (BGH, GRUR-RS 2020, 41776, Rn. 63 – 68 und Rn. 77 – FRAND-Einwand II). 423

II. 424

Für eine Aussetzung der Verhandlung gemäß § 148 ZPO im Hinblick auf die das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage besteht derzeit kein Anlass. Es ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass das Klagepatent nicht wegen mangelnder Patentfähigkeit der Erfindung vernichtet wird. 425

1.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lehre des Klagepatentanspruchs 1 neu und erfinderisch ist. 426

a)

Die Entgegenhaltung US ´X (Anlage B 4) nimmt den Gegenstand des Klagepatentanspruchs 1 nicht neuheitsschädlich vorweg. Sie offenbart nicht unmittelbar und eindeutig das Merkmal 1e. 427

aa) 428

Bei der Entgegenhaltung US `X handelt es sich um Stand der Technik. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass das Klagepatent die Priorität vom 22. April 2002 nicht wirksam in Anspruch nimmt und daher der 12. Juli 2002 als frühester Zeitrang in Betracht kommt. 429

bb) 430

Das Merkmal 1e darf im Rahmen der Neuheitsprüfung nicht außer Acht gelassen werden, denn es weist die für die Patentierbarkeit notwendige Technizität auf. 431

Nach § 1 Abs. 1 PatG kommen als Gegenstand einer Erfindung nur technische Lehren in Betracht, wobei es genügt, wenn die Lehre überhaupt technischen Charakter aufweist. Insofern ist auch eine Kombination von technischen und nicht-technischen Merkmalen grundsätzlich patentfähig (Benkard, PatentG, 11. Aufl. 2015, § 1 Rn. 45 ff.). 432

Ausgeschlossen vom Patentschutz sind insofern mathematische Methoden, da diese keine Anweisung zum technischen Handeln enthalten. So enthalten beispielsweise Algorithmen in der Regel Vorgaben, mit deren Hilfe nach den im Einzelnen festgelegten Regeln eine schrittweise Abwicklung von Arbeiten und Arbeitsgängen ermöglicht wird. Ihr Ziel ist regelmäßig allein die Lösung von Problemen mit Hilfe der Logik; auf die Hilfe der Naturkräfte wird allenfalls bei ihrer tatsächlichen Umsetzung zurückgegriffen (Benkard, aaO, Rn. 98 ff.). 433

Nach diesen Grundsätzen stellt sich der nach Merkmal 1e durchzuführende Ma? trixvorgang zwar als mathematische Methode dar, die für sich genommen dem Patentschutz nicht zugänglich ist. Sie ist hier jedoch in eine technische Handlungsanweisung eingebettet, bei der es sich um das Transformieren des Eingangssignals und des gefilterten Signals in die beiden Ausgangssignale handelt. Dass dieser Vorgang sich mithilfe eines Matrixvorgangs abbilden lässt, ändert nichts an der Technizität als solcher. Im Rahmen der Neuheitsprüfung hat dies aber zur Folge, dass es für eine neuheitsschädliche Vorwegnahme nicht darauf ankommt, dass der zum Transformieren notwendige Vorgang als Matrix dargestellt ist, sondern allein darauf, ob sich dieser grundsätzlich als solcher darstellen lässt. 434

cc) 435

Die Entgegenhaltung US `287 offenbart das Merkmal 1e nicht eindeutig und unmittelbar, da sie keine der erfindungsgemäßen Lehre entsprechende Mischung des Eingangssignals und des gefilterten Signals als Grundlage für die Ausgangssignale L und R offenbart, die sich durch einen Matrixvorgang darstellen lässt, also als Linearkombination des Eingangssignals und des gefilterten Signals. Bereits aus der Figur 3 der US ´287 ist erkennbar, dass das rechte Signal ausschließlich auf der Grundlage des gefilterten Signals S‘ erzeugt wird und keinen Anteil des Eingangssignals S enthält. Anders als durch das Klagepatent ist damit keine Lehre offenbart, bei der beide Ausgangssignale grundsätzlich aus Anteilen des Eingangssignals und des gefilterten Signals bestehen können. Dagegen kann nicht mit Erfolg eingewendet werden, dass der Matrixkoeffizient, der den Anteil des Eingangssignals in einem der Ausgangssignale bestimmt, auch Null betragen könne. Vielmehr ist die Lehre des Klagepatents dahingehend zu verstehen, dass es grundsätzlich möglich sein muss, dass beide Signale einen Anteil des Eingangssignals enthalten; nur ausnahmsweise, wenn nämlich beide Signale nicht korreliert sind und ein bestimmtes Signal nur in einem der beiden Signale enthalten ist, kann der Anteil des Eingangssignals beziehungsweise des gefilterten Signals Null sein (siehe Absatz [0038]). Das offenbart die US `287 jedoch nicht. Stattdessen enthalten beide Ausgangskanäle immer einen Anteil des gefilterten Signals S‘, das im Fall des Ausgangssignals L mit dem Eingangssignal S und im Fall des Ausgangssignals R mit dem weiter gefilterten Signal S‘‘ kombiniert wird. Damit verwendet die Entgegenhaltung nicht nur das Eingangssignal und das gefilterte Signal, sondern drei verschiedene Signale zur Bildung der Ausgangssignale. 436

b)

Auch die Entgegenhaltung WO ´X (Anlage B 5) nimmt die erfindungsgemäße Lehre nicht neuheitsschädlich vorweg. Es fehlt an der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung von Merkmal 1e. 437

Die beiden Ausgangssignale stellen sich nicht als Linearkombinationen des Eingangssignals und des gefilterten Eingangssignals dar, also als Summen der mit Matrix-Koeffizienten multiplizierten Eingangssignale. Vielmehr scheint die WO ´656 ausweislich der Figur 2a das Eingangssignal durch den Hochpass 201 und den Tiefpass 203 nach seinen Frequenzen aufzuteilen und den mit dem Hochpass gefilterten Teil des Eingangssignal mit einer Stereobreite W zu versehen, die als Korrelationsparameter zur Berechnung zweier Ausgangssignale aus dem gefilterten Eingangssignal angesehen werden kann, die am Ausgang des WIDTH-Blocks 205 bereitgestellt werden. Zu diesen beiden Ausgangssignalen wird dann der mit dem Tiefpass gefilterte Teil des Eingangssignals addiert. 438

Nach der Entgegenhaltung B 5 fließt damit das (ungefilterte) Eingangssignal nicht in das Ausgangssignal ein. Dem kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass eine Filterung der Signale regelmäßig vorgenommen wird und es unschädlich ist, wenn das Eingangssignal unabhängig von dem gefilterten Signal ebenfalls gefiltert wird. Funktional geht es darum, das (ungefilterte) Eingangssignal und das gefilterte Signal ähnlich dem Stand der Technik gemäß Absatz [0006] so zu kombinieren, also zu addieren und zu subtrahieren, dass ein Linkskanal und ein Rechtskanal entsteht, wobei sich das Eingangssignal und das gefilterte Signal denknotwendig auf dasselbe Frequenzband beziehen. Das ist bei der Entgegenhaltung B 5 aber nicht der Fall. Denn es erfolgt lediglich eine Aufspaltung des Eingangssignals in ein Hochfrequenzband und ein Niedrigfrequenzband, die nachher wieder zum vollständigen Ausgangssignal zusammengesetzt, sprich: addiert werden. Unterschiedliche Ausgangskanäle entstehen nur dadurch, dass das Hochfrequenzsignal im Block 205 eine Stereobreite erhält. Ein Korrelationsparameter findet auf das Eingangssignal also überhaupt keine Anwendung, sondern allenfalls auf den Teil des Signals, der das Hochfrequenzband bildet. Bei gesonderter Betrachtung dieses Frequenzbands als Eingangssignal M in Figur 2b wird die Lehre des Klagepatentanspruchs jedoch auch nicht offenbart, weil es an einer Filterung des Signals und an einem Matrixvorgang fehlt, der dieses Signal M und ein etwaiges gefiltertes Signal M‘ zum Gegenstand hätte. Selbst wenn sich also die Signalerzeugung nach Figur 2a und 2b der Entgegenhaltung B5 letztlich in irgendeiner Form als Matrixvorgang beschreiben lässt, handelt es sich nicht um einen Matrixvorgang im Sinne von Merkmal 1e. 439

Soweit das japanische Parallelpatent zum Klagepatent aufgrund der Entgegenhaltung B 5 nicht ohne weiteres erteilt wurde, sondern nur in einer eingeschränkten Fassung, ergibt sich daraus nichts anderes. Zunächst liegt die Mitteilung des japanischen Patentamts lediglich in einer englischen Maschinenübersetzung vor, die bereits keinen zuverlässigen Rückschluss auf die Gründe für die Zurückweisung der japanischen Patentanmeldung zulässt. Es hat den Anschein, dass das japanische Patentamt von der mangelnden Patentfähigkeit der Anmeldung unter der Prämisse ausgeht, dass die Reihenfolge von Verstärker 215, Filter 217 und Verzögerungsschaltung vertauscht, insbesondere der Verstärker hinter der Verzögerungsschaltung angeordnet ist. In dieser Konstellation ist der Decodierer in der B 5 jedoch nicht offenbart, jedenfalls ist das so nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich. Von einer neuheitsschädlichen Offenbarung der patentgemäßen Lehre kann insofern nicht ausgegangen werden. 440

c)

Die Entgegenhaltung von Schroeder „An Artificial Stereophonic Effect Obtained from a Single Audio Signal“ (Anlage B 6) nimmt die erfindungsgemäße Lehre nicht neuheitsschädlich vorweg. 441

Es kann offenbleiben, ob in dem aus Figur 2 der Entgegenhaltung ersichtlichen Parameter ? ein Korrelationsparameter gesehen werden kann. Jedoch lässt die Entgegenhaltung nicht in eindeutiger und unmittelbarer Weise einen Pegelparameter im Sinne von Merkmal 1d erkennen. Die Beklagten tragen vor, dass sich die Pegeldifferenz durch die in der Figur 2 erkennbare Addition der Signale f(t) und (t-?) ergebe. Auch wenn es sich dabei um eine nach Ansicht der Beklagten „bewusst gewählte Gewichtung“ handeln mag, ist ein Pegelparameter als solcher, der indikativ für eine gewünschte Pegeldifferenz ist, der Entgegenhaltung nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen. 442

Im Übrigen ist ein „Erhalten“ eines Korrelationsparameters bzw. eines Pegelparameters im Sinne der Merkmal 1c und 1d nicht offenbart. Das Klagepatent geht für das Verfahren davon aus, dass die Parameter zugeführt und dann in die Berechnung zur Synthetisierung der beiden Ausgangssignale, den Matrixvorgang, einbezogen werden. 443

d)

Bei der Entgegenhaltung Faller et al, „Efficient Representation of Spatial Audio Using Perceptual Parametrization“ (Anlage B 7) handelt es sich um geprüften Stand der Technik, der eine Aussetzung der Verhandlung grundsätzlich nicht zu rechtfertigen vermag. Zudem fehlt es an der Filterung des Eingangssignals und an einem Matrixvorgang im Sinne der Merkmale 1b und 1e. Ausweislich der Gleichung (3) der Entgegenhaltung wird das Ausgangssignal S lediglich mittels von ?L_n und ?$_n$ abhängiger Faktoren auf zweierlei Art und Weise parametrisiert. Eine Filterung findet nicht statt. Selbst wenn man mit der Beklagten das mittels ?$_n$ parametrisierte Signal als S‘ ansehen wollte, fehlt es weiterhin an einem Matrixvorgang, der dieses gefilterte Signal mit dem Eingangssignal mischt. Stattdessen bestehen die beiden Ausgangssignale entweder nur aus dem parametrisierten Eingangssignal S oder dem parametrisierten Ausgangssignal S‘. Zur weiteren Begründung kann auf die Ausführungen zur Entgegenhaltung US ´287 (Anlage B 4) verwiesen werden. 444

e)

Die Entgegenhaltung WO ´X (Anlage B 8) ist von der Lehre des Klagepatents noch weiter entfernt und nimmt sie nicht neuheitsschädlich vorweg. Es fehlt bereits an der Offenbarung der Merkmale 1d und 1e. Ein gesonderter Pegelparameter wird von der Schaltung nicht erhalten. Ein Matrixvorgang ist aus denselben Gründen wie im Fall der Entgegenhaltung WO X (Anlage B 5) nicht vorhanden. Daher kann die Lehre des Klagepatents auch nicht als im Stand der Technik nahegelegt angesehen werden. Es ist nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, das Erhalten eines gesonderten Pegelparameters vorzusehen, der dann im Rahmen des Matrixvorgangs Berücksichtigung findet. Denn die Ausgangskanäle weisen durch die Summen- bzw. Differenzbildung automatisch die Pegeldifferenz der Ursprungskanäle auf. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der in der Entgegenhaltung offenbarten Schaltung, mit der zwei Signale über variable Gewichtungsfaktoren miteinander 445

verknüpft werden, da nicht ersichtlich ist, warum der Fachmann eine davon abweichende Lösung finden soll. An einem Matrixvorgang fehlt es ohnehin.

f)

Aufgrund der zu den vorangehenden Entgegenhaltungen aufgestellten Erwägungen stellt auch die US ´962 (Anlage B 9) die Patentfähigkeit der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 nicht in Frage. Denn es fehlt am Erhalten eines Korrelations- oder Pegelparameters (Merkmal 1c und 1d). Welchen Anlass der Fachmann haben sollte, beide Parameter im Rahmen eines erfindungsgemäßen Matrixvorgangs zur Synthetisierung zweier Stereokanäle aufzunehmen, ist nicht dargelegt. Dass im Stand der Technik solche Parameter für sich genommen bekannt waren, genügt insofern jedenfalls nicht. Zudem fehlt es an der Offenbarung von Merkmal 1e, weil die Entgegenhaltung B 9 lediglich die Verwendung einer Differentialgleichung offenbart, die sich nicht als Linearkombination im Sinne eines Matrixvorgangs ausdrücken lässt. 446

2.

Aus den vorstehenden Erwägungen zum Anspruch 1 des Klagepatents ist auch für den Anspruch 7 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er sich im Nichtigkeitsverfahren als patentfähig erweisen wird. Das gilt auch mit Blick auf die von den Beklagten angeführte Rechtsprechung zu Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben. Da der Klagepatentanspruch 7 in den Merkmalen 7c und 7d ausdrücklich Mittel zum Erhalten von Korrelations- und Pegelparameter vorsieht, die in der Entgegenhaltung Schroeder (Anlage B 6) als solche nicht offenbart sind, erweist sich Anspruch 7 auch in dieser Hinsicht als neu. Ähnliches gilt für die Entgegenhaltung Faller (Anlage B 7), weil der erfindungsgemäße Matrixvorgang nicht nur eine reine Rechenoperation darstellt, sondern auch funktional bestimmte Anforderungen an die schaltungstechnische Anordnung zum Erhalt der so definierten Ausgangskanäle stellt – hier: zweier Ausgangskanäle, die sich jeweils als Summe des mit entsprechenden Matrixkoeffizienten multiplizierten Eingangssignals und des ebenfalls mit entsprechenden Matrixkoeffizienten multiplizierten gefilterten Eingangssignals darstellen. Daran fehlt es hier aus den zum Patentanspruch 1 ausgeführten Gründen. 447

C

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 und 2 ZPO, wobei die Zuvielforderung gegenüber der Beklagten zu 2) so gering war, dass ihr diesbezüglich die gesamten Kosten (mit Ausnahme des Anteils der Beklagten zu 1)) aufzuerlegen waren. 448

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckung ergibt sich aus § 709 S. 1 und 2 ZPO. Dem von den Beklagten hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutzantrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht haben. 449

D

Streitwert: 1.000.000 EUR, wobei 100.000 EUR auf die gesamtschuldnerische Verpflichtung zum Schadensersatz entfallen. 450

Justiz NRW
Rechtsprechungsdatenbank ONLINE